

CAPÍTULO V

LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS

1. Introducción

En el segundo capítulo de este libro se ha intentado una caracterización de las normas jurídicas que las vinculaba con ciertos usos del lenguaje.

De ello no se infiere que, para que una norma exista, tenga necesariamente que haberse realizado un acto lingüístico.

Muchas veces las normas no se verbalizan, sino que se presuponen implícitamente cuando se reacciona en cierto sentido frente a determinadas circunstancias. Así ocurre con las normas consuetudinarias y en parte también con las jurisprudenciales. Para que sea verdad, por ejemplo, que entre los comerciantes rige una norma que prescribe considerar el pago dentro de los 30 días como pago al contado, no es necesario que alguien haya pronunciado la oración "el pago dentro de los 30 días a partir de la operación debe ser considerado como pago al contado". Basta con que los comerciantes reaccionen de igual forma ante ambas modalidades de pago y critiquen a los que no lo hagan. Sin embargo, cualquier norma es expresable, aunque no haya sido expresada de hecho, mediante oraciones lingüísticas. Ello permite considerar las normas como el significado de ciertas oraciones, así como las proposiciones constituyen el significado de otras.

En el caso de la mayor parte de las normas jurídicas se recurre al lenguaje a fin de promulgarlas. Esto es propio del derecho creado deliberadamente, aunque es dable pensar en normas de este tipo que se hagan conocer por medios no lingüísticos. Se podría imaginar un derecho primitivo en el cual el legislador tea-

tralizara las conductas que deseara obtener de sus súbditos. Y aun en el mismo derecho moderno basta recordar muchas normas de tránsito que se hacen explícitas mediante carteles en los que sólo aparecen ciertas flechas o dibujos.

Cuando las normas se sancionan o se transmiten no por medio del lenguaje sino por vía de la ejemplificación de los comportamientos que se ajustan a ellas, hay que determinar qué aspectos de tales acciones están regulados normativamente, lo cual puede envolver ciertas dificultades. Hart da el ejemplo de un niño a quien su padre le enseña ostensivamente la regla que dispone sacarse el sombrero en la iglesia; observando a su padre, el niño puede dudar de si lo que está prescripto es sólo sacarse el sombrero o hacerlo con la mano izquierda, o con un ademán particular, etcétera.

En las normas que se comunican utilizando símbolos, lingüísticos o no, la determinación de qué norma ha sido sancionada presupone la actividad de *interpretar* tales símbolos, o sea de atribuirles significado.

La tarea de establecer qué regla subyace a una regularidad de conductas o a una frase lingüística, se plantea en forma acuciante cuando hay que decidir, por un “sí” o un “no”, la aplicabilidad de la norma a un caso concreto. Cuando se está en esa tarea, no basta decir que existe una norma que prescribe sacarse el sombrero en la iglesia; hay que resolver, por ejemplo, si la prescripción rige también para los no creyentes; no es suficiente concluir que la expresión “matar” que utiliza el art. 79 del Cód. Penal argentino significa quitar la vida a un hombre, sino que deberemos decidir, por ejemplo, si cubre un caso como el de quien omite salvar la vida de otro, teniendo el deber de hacerlo.

Todos nosotros deliberamos cotidianamente acerca de la aplicación de normas a ciertos casos, ya para planear futuras conductas, ya para evaluar acciones cometidas en el pasado.

Respecto de las normas jurídicas hay, sin embargo, un cuerpo de funcionarios, los jueces, cuya opinión es privilegiada en cuanto a la aplicación de una norma a un caso, puesto que el pronunciamiento de esa opinión es condición para que se hagan efectivos los efectos que las normas establecen.

Los jueces, en los Estados modernos, enfrentan generalmente normas promulgadas a través de un lenguaje y, en la inmensa mayoría de los casos, de un lenguaje escrito.

Los legisladores utilizan un lenguaje natural, como el castellano, hablado por sus súbditos, ya que generalmente están interesados en comunicar sus directivas en la forma más eficaz posible, lo cual obviamente no conseguirían si emplearan un idioma extranjero o un lenguaje privado.

La formulación de normas utilizando un lenguaje corriente hace que la expresión de la intención del legislador se encuentre limitada por los defectos que, como veremos más adelante, presentan los lenguajes naturales.

Además, el uso de un lenguaje natural compromete al legislador con la consecuencia de que sus expresiones sean interpretadas de acuerdo con el significado que a ellas les atribuyen las costumbres lingüísticas del grupo social al que las normas van dirigidas. Es verdad que, como luego veremos, los símbolos lingüísticos no tienen por qué tener otro significado que el que les otorga quien los usa. Sin embargo, esto se encuentra condicionado, en el derecho, por la dificultad de conocer la intención de los legisladores, a los que muchas veces sobreviven sus normas, y por la convención, vigente en la dogmática actual, de que la intención del legislador no es un criterio decisivo para atribuir significado a sus palabras, sino que tienen prelación sobre él la determinación de cómo serían razonablemente interpretadas por sus destinatarios y las consideraciones acerca de la relación que debe guardar la norma en cuestión con otras que integran el sistema jurídico.

Así, pues, no es del todo exagerado sostener que los jueces se encuentran vinculados, en el derecho legislado, no por un conjunto de normas, sino por una serie de oraciones cuyo significado es asignado de acuerdo con ciertas reglas semánticas y sintácticas, las haya tomado o no en cuenta el propio legislador. Una coma, quizá mal colocada, constituye para los jueces un obstáculo mucho más grave que la supuesta intención del legislador acerca del sentido de una palabra, puesto que los tribunales no pueden alterar, borrando o tachando, lo que está escrito en un texto legal, pero sí pueden adaptar el significado de las expresiones lingüísticas a usos lingüísticos diferentes de los seguidos por el legislador.

También los legisladores están condicionados, en la expresión de su intención, por las leyes y reglas de inferencia lógica. Un análisis lógico de los enunciados legislativos puede llevar a descalificarlos o a mostrar consecuencias no previstas por sus autores.

Debe tenerse en cuenta que las normas que un legislador sanciona, se insertan en un sistema integrado también por otras normas; por lo cual, de la combinación de las normas que un legislador dicta con las otras que ya pertenecen al sistema o formen parte de él en un futuro, podrán derivarse consecuencias no advertidas quizá por dicho legislador, o bien surgir problemas lógicos —como contradicciones, lagunas, redundancias— que no se presentan en las normas aisladas, sino una vez que entran en relación con el resto del sistema jurídico.

En lo que sigue se mostrarán algunos problemas de índole semántica y sintáctica con que puede tropezar la interpretación de los textos legales; luego se analizarán otros de carácter lógico.

Antes de revisar las dificultades de índole lingüística que plantea la interpretación jurídica, conviene exponer las características que presentan los lenguajes naturales.

2. Algunos aspectos del lenguaje que hablamos

a) *Las palabras y su relación con la realidad*

Como muchas veces se ha dicho en las introducciones al tema del lenguaje, las palabras constituyen *símbolos* para representar la realidad, así como lo son también las notas musicales, las sirenas de las ambulancias, las luces de los semáforos, las banderas de los marinos, etcétera.

Los símbolos deben distinguirse de los *signos*, que tienen una relación natural o causal con el objeto que representan: así, el trueno respecto del rayo, el humo con relación al fuego, el llanto de un niño pequeño respecto de su hambre. En cambio, los símbolos tienen sólo una relación convencional con los objetos representados; la representación no emana de una conexión causal con el fenómeno representado, sino de convenciones establecidas implícitamente por los hombres; es decir, de reglas que permiten hacer referencia a ciertos hechos, cosas, relaciones, usando determinadas figuras, ruidos, objetos, etcétera.

La utilidad de tener presente la distinción entre símbolos y signos y de advertir que el lenguaje es un sistema del símbolos, se pone de manifiesto cuando reparamos que existe una tendencia en el pensamiento común, racionalizada por alguna tradición

filosófica prestigiosa, que encara las palabras como si fueran signos, o sea, como si tuvieran una relación natural, independiente de la voluntad de los hombres, con aquello que significan.

Esta idea fue considerada ya en otras partes de este trabajo bajo el rótulo que le da Carnap, de "concepción mágica del lenguaje", o el que emplea Kantorowicz, de "realismo verbal".

Carnap dice que el niño que comienza a hablar se siente inclinado a suponer que las palabras que usa para hacer referencia a las cosas son las naturalmente apropiadas para hacerlo, mientras que otras expresiones, por ejemplo las de idiomas extranjeros, son erróneas o estrambóticas. El adulto es más tolerante con el hecho de que otros pueblos denominen las mismas cosas con otras palabras, pero de cualquier modo se conserva siempre la impresión inconsciente de que lo natural es llamar "casa" y no "house" o "maison" a lo que, en realidad, es una casa.

El mismo autor muestra cómo se refleja este prejuicio en filósofos y científicos que deberían estar exentos de él. En particular, gran parte de la resistencia al uso del lenguaje cuantitativo por parte de la ciencia tiene su origen, como lo muestra Carnap analizando ciertos argumentos en ese sentido, en la idea de que la forma natural de designar, por ejemplo, una temperatura determinada, es hacerlo con la palabra "frío", y no, pongamos por caso, con la expresión "0°".

La idea de que el significado de las palabras está determinado por la realidad, como si fuera un reflejo de algún aspecto importante de ella, tiene carta de ciudadanía filosófica con el esencialismo. Esta posición, que admite muchas variantes y formulaciones diferentes, pero cuyos rasgos fundamentales fueron esbozados por Platón, sostiene en definitiva que hay ciertas propiedades no empíricas que hacen que las cosas sean lo que son; que, en consecuencia, se diferencian de las cualidades accidentales que las cosas pueden o no poseer, pero que deben reflejarse en el significado de las palabras con que se las nombra.

A esta idea alude Jorge Luis Borges con ironía, en estos deliciosos versos varias veces citados:

"Si el nombre es el reflejo de la cosa
(como dice el griego en el Cratilo),
en las letras de 'rosa' está la rosa
y todo el Nilo en la palabra 'Nilo'."

Según esta tradición filosófica, hay un "verdadero" y "único" significado de las expresiones del lenguaje, que debe ser captado investigando una misteriosa realidad no empírica.

Preguntas como "¿qué es el hombre?" "¿qué es el derecho?" "¿qué es el bien?", son totalmente indiferentes a cualquier hecho

acerca del lenguaje y se debe responder a ellas expresando la "esencia" o "naturaleza" de tales entidades.

Es importante advertir que las preguntas como las que se acaba de mencionar, son ambiguas.

Cuando se inquiere "¿qué es X?" o "¿qué significa X?", se puede requerir tanto una especificación del significado de la expresión "X" (u "hombre", o "derecho", o "bien"), como una información acerca de determinadas cualidades que de hecho presentan las cosas o fenómenos nombrados con tales palabras (el derecho, los hombres, las cosas buenas, etcétera).

En el primer caso, la pregunta se responde señalando en qué condiciones se usa la expresión de que se trata; la respuesta debe, entonces, consistir en una información acerca del lenguaje, y no acerca de la realidad mencionada por él, salvo en el aspecto obvio de que definir una palabra implica acotar los hechos a que la palabra se refiere. En el segundo caso, en el cual se presupone un significado de la palabra y en consecuencia se pueden identificar los hechos que ella denota, se responde señalando algunas de las propiedades que tales hechos presentan en la realidad.

Ambas cuestiones aparecen confundidas en muchos trabajos de los juristas. Por ejemplo, los penalistas se preguntan "qué es el delito", y las respuestas que dan a este interrogante incluyen por lo común, confusamente, tanto una enunciación de las condiciones para el uso de la palabra "delito", como una descripción de algunas propiedades que los hechos designados por esa expresión presentan según las exigencias contingentes de determinado ordenamiento jurídico.

El factor que provoca la confusión entre ambos tipos de pregunta, es la adhesión a la concepción esencialista. Si se piensa que las condiciones para el uso de una palabra están determinadas por la realidad y no por ciertas reglas del lenguaje convenidas por la gente, elucidar, por ejemplo, el concepto de hombre requerirá, no un relevamiento de los casos a que se aplica la palabra "hombre", sino detectar ciertas propiedades de los hombres, del mismo modo, aunque usando procedimientos cognoscitivos diferentes, que cuando se pregunta por el origen de los seres humanos o acerca de su expectativa de vida.

Muchos de los problemas que parecen más arduos en la filosofía y las ciencias (expresados en preguntas como ¿qué es en realidad el ser? ¿cuál es el verdadero concepto de justicia? ¿qué es la materia?), pierden mucho de su misterio y de la

perplejidad que suscitan, una vez que los traducimos a preguntas acerca del uso de ciertas expresiones del lenguaje.

El esencialismo conceptual se muestra también en la preferencia que tienen muchos pensadores, entre ellos los juristas, por el análisis etimológico de las palabras como medio para determinar su significado. Si se supone que las palabras poseen un único y verdadero significado, determinar el procedimiento de formación de las expresiones lingüísticas podrá servir de guía para detectar el concepto que quisieron captar quienes le dieron origen a la palabra y que se supone que debe mantenerse incólume en sus futuros usos.

Pero el análisis etimológico constituye una pauta muy poco confiable para establecer el significado de las palabras, pues el procedimiento seguido para inventar un ruido, un fonema o una grafía, aun cuando se lo haya hecho por derivación o combinación de otros sonidos, palabras o rasgos, no determina necesariamente el uso que a tal ruido, fonema o grafía haya de dársele de hecho. Imagínese, si no, lo poco eficaz que sería enseñar a un extranjero el significado de "televisión" o de "Argentina" sobre la base de un análisis etimológico: el pobre aprendiz de nuestro idioma llamaría probablemente "televisión" a un catalejo, y "Argentina" a un país donde abunda la plata.

Cuando decimos que la relación entre los símbolos lingüísticos y la realidad es convencional y no natural, no significamos solamente que la palabra que denota una clase de objetos, designando propiedades comunes a ellos, podría ser reemplazada por otra, como ocurre efectivamente en otros idiomas. Se quiere decir también que el mismo término podría tener un significado diferente del que posee en el lenguaje ordinario y que hay libertad para otorgárselo sin incurrir en falsedad (aunque dificultando la comunicación).

La verdad o falsedad está en relación con los enunciados y no con las oraciones. Es decir que si expresamos el mismo enunciado con palabras diferentes de las que suelen usarse para expresarlo en el lenguaje habitual (por ejemplo, si dijéramos "no tengo nada de pan", usando la palabra "pan" con significado equivalente al de "dinero") el valor de verdad del enunciado no varía.

b) El significado de las palabras

Cuando se habla del significado de las palabras, se suele aludir tanto a su *denotación* (o extensión) —la clase de cosas o hechos nombrada por la palabra—, como a su *designación* (o connotación o intensión) —el conjunto de propiedades que deben

reunir las cosas o hechos para formar parte de la clase denotada por el término.

La designación y la denotación de una palabra están en función recíproca. Si la designación se amplía (por ejemplo, porque antes se exigían las propiedades *A* y *B* para que un objeto integrara la clase y ahora se requieren *A*, *B* y *C*), la denotación posible de la palabra se restringe, porque hay potencialmente menos objetos que reúnan un mayor número de propiedades definitorias. A la inversa, una exigencia menor en cuanto a la designación de la palabra, lleva a una extensión mayor de la denotación potencial de ella.

Lo que decimos se refiere a las llamadas “palabras de clase”. Estas palabras no se distinguen de los nombres propios por el hecho, como a veces se dice, de que las palabras de clase denoten muchos individuos mientras que los nombres propios sólo se refieren a uno (que esto no es así lo demuestran expresiones de clase, como “unicornio”, que no denotan ningún individuo real, y nombres propios como “Juan Pérez”, que designan una gran cantidad de individuos). La distinción radica en que las palabras de clase, además de denotar cosas, *designan* propiedades que deben poseer tales cosas para que sean denotadas por la palabra correspondiente; los nombres propios, en cambio, denotan sin designar: no hay ninguna propiedad común con los otros Juan Pérez que deba haber tenido en cuenta el padre de un recién nacido para ponerle ese nombre.

Las palabras de clase suponen, pues, haber hecho una clasificación de la realidad.

Clasificar consiste en agrupar teóricamente cosas o hechos, tomando en cuenta ciertas propiedades comunes.

Si lo pensamos bien advertiremos que cualquier par de cosas tienen en común alguna propiedad y podrían, por tanto, ser incluidas en la misma clase; y cualquier par de cosas tienen alguna propiedad diferente, lo cual nos permitiría incluirlas en clases distintas.

Por lo tanto, la tarea de hacer una clasificación supone seleccionar como relevantes ciertas propiedades que posean en común determinadas cosas, haciendo caso omiso de otros rasgos semejantes y de las propiedades diferentes que puedan tener. Esta selección tampoco está determinada por la realidad (las cosas no claman: “¡tomad mi redondez y no mi peso para clasificarme!”), sino que simplemente se la hace tomando en cuenta la necesidad

que quiere satisfacerse con la clasificación. Desde luego que el hecho de tomar en cuenta ciertas semejanzas entre las cosas para incluirlas en la misma clase dejando de lado otras analogías y sus diferencias, no implica negar que tales otras semejanzas y diferencias se den en la realidad. Sólo supone el compromiso de no incluir en una clase constituida a partir, por ejemplo, de la propiedad A, en consideración a ciertos fines, ningún objeto que no reúna esa propiedad, independientemente de que posea o no muchas otras analogías con las de los objetos que integran la clase.

Esto que parece tan simple, sin embargo es negado implícitamente por muchos. Algunas de las impugnaciones al pensamiento "abstracto" expresan el disgusto de que se clasifiquen las cosas y se definan las palabras con que se las nombra considerando sólo algunas propiedades como relevantes y no todas las que se dan en la realidad. Poniendo un ejemplo: muchos juristas suponen que, por el hecho de definir la palabra "acción" sin considerar como definitiva la intención del agente, según lo propone la teoría causal de la acción en derecho penal, se niega que las acciones sean intencionales.

Pretender que todas las propiedades de una cosa sean definitivas de las palabras con que se las denomina, es un disparate teórico que proviene de una confusión acerca del funcionamiento del lenguaje. Si se tomara en serio esa idea, tendría que haber una palabra para cada objeto; cualquier propiedad que predicáramos de las cosas estaría presupuesta ya por el significado de las palabras con que las nombráramos, con lo cual nuestros enunciados nunca dirían nada nuevo para quienes usaran el mismo lenguaje. El pensamiento, tanto el corriente como el científico, incluso el de quienes abogan por el pensamiento "concreto", requiere un esquema conceptual apoyado en clasificaciones que tomen sólo algunas propiedades de las cosas como relevantes para nombrarlas con ciertas palabras, de modo que se puedan usar luego las palabras para describir las características contingentes con que se presentan en la realidad tales cosas.

Quizás esto se comprenda mejor si distinguimos diferentes grupos de propiedades que pueden tener las cosas en relación con el lenguaje. Algunas de las propiedades de las cosas son *definitorias* de las palabras con que se las nombra. Son las características que constituyen la designación de un término; su ausencia en una cosa o hecho da lugar a que la palabra en cuestión no le sea aplicable. Por supuesto, que una propiedad que en un momento es definitiva de una expresión lingüística puede dejar de serlo si cambia el uso del término. Los enunciados que predicen una propiedad definitiva no son empíricos, no hacen referencia a la realidad, sino al significado de la palabra que se define por esa

propiedad. Por ejemplo, si se dice “las lapiceras son objetos para escribir”, no se da ninguna información acerca de las lapiceras— ni siquiera se dice que exista en el mundo algún objeto de esa índole—, sino que se habla acerca del significado de la palabra “lapicera”; lo cual no puede ser falseado por ningún hecho que ocurra en el mundo (salvo que cambie el uso de la palabra).

Las propiedades de una cosa, que no son definitorias de la palabra con que se la nombra, suelen calificarse de *concomitantes*. Su presencia no es necesaria ni suficiente para el uso del término.

Algunas de las propiedades concomitantes son *contingentes*, en el sentido de que unos objetos de la clase las poseen y otros no. Por ejemplo, el ser de raza blanca es una propiedad concomitante contingente en la clase de los hombres. Otras características concomitantes son *universales*, puesto que, de hecho, aparecen en todos los individuos de la clase. Por ejemplo, el medir menos de cuatro metros es una propiedad que poseen todos los miembros de la clase designada con la palabra “hombre”. Las propiedades concomitantes universales se distinguen de las definitorias por el hecho de que, a pesar de que las primeras se dan en la realidad siempre juntas con las definitorias, no son indispensables para el uso del término; de tal modo que si, hipotéticamente, apareciera una cosa que reuniera las propiedades definitorias de la palabra pero no las universalmente concomitantes, la palabra se aplicaría lo mismo (como acaecería si aparecieran hombres de más de cuatro metros de altura).

La acción y el resultado de establecer el significado de una palabra se llama *definición*.

Se suelen distinguir diversas clases de definición, según varios criterios.

Uno de tales criterios toma como relevante la finalidad, por un lado, de informar acerca de cómo la gente en general o alguien en particular usa una palabra, y por el otro, de decidir, prescribir, recomendar cierto uso de un término.

En el primer caso se trata de una definición *informativa* o *lexicográfica*, que será verdadera o falsa según su correspondencia o no con el uso que pretende describir (un ejemplo de este modo de definición sería: “en la Argentina se usa la expresión *traje* para hacer referencia a un atuendo de saco y pantalón”).

En el segundo caso, estamos frente a una definición *estipulativa*, que no puede ser verdadera ni falsa, puesto que con ella

no se pretende describir un uso lingüístico sino expresar una decisión o directiva acerca del significado que habrá de darse a una palabra (por ejemplo, “usemos el término *delito* para hacer referencia sólo a las acciones castigadas con prisión”). El parámetro para evaluar las definiciones estipulativas es su utilidad para la comunicación, o para la configuración de un esquema conceptual preciso.

Los diccionarios pretenden formular definiciones informativas acerca del uso de las palabras. Sin embargo, hay ciertos diccionarios, como el de la Real Academia Española, que no se limitan a describir usos lingüísticos, sino que tratan de normarlos, formulando definiciones estipulativas que prescriben que se sigan algunos de los usos vigentes y no otros.

Las definiciones se pueden clasificar también por el *método* que emplean para transmitir los criterios del uso de las palabras.

El método directo, aunque más difícil, es el de formular la *designación* del término. Es decir que se enuncian las propiedades definitorias de la expresión que se pretende definir. Por ejemplo: “vamos a usar la palabra *derecho* para designar un sistema de normas entre cuyas consecuencias esté la permisión u obligación de un acto coactivo”; o bien “el hombre es un animal racional”, o “triángulo es una figura cerrada de tres lados”. Cuando la definición pretende ser informativa, este método no resulta sencillo, puesto que los criterios para el uso de una palabra son, en general, seguidos en forma no consciente.

Otro método, muy usado, de definición consiste en la mención de algunos miembros de la *denotación* de la palabra. Puede hacerse designando, tanto subclases de la clase denotada, como individuos particulares. Por ejemplo: “con la palabra *profesional* denominamos abogados, médicos, dentistas, etc.”; o bien: “abogados son, por ejemplo, Alberto Mansur, Norberto Spolansky y María Eugenia Urquijo”. El problema de este modo de definiciones es que se puede fracasar en el intento de comunicar con precisión cuáles son los criterios para el uso del término, dando lugar a que a veces se tome como definitorias ciertas propiedades que son contingentes a los ejemplos mencionados (por ejemplo, en el caso de la definición denotativa de “abogado” que hemos ofrecido, se podría suponer erróneamente, a partir de los ejemplos dados, que la lucidez intelectual fuera una propiedad definitoria de dicha palabra).

También se puede definir una palabra *ostensivamente*, es

decir, pronunciando la expresión de que se trate y señalando algún objeto denotado por ella. La diferencia con la definición denotativa reside en que en la ostensiva no se mencionan verbalmente los ejemplos de la denotación, sino que se los muestra directamente. Esta es la manera más frecuente de enseñar a hablar a los niños. La definición ostensiva tiene el mismo inconveniente que la que se hace por denotación, ya que puede dar lugar a que se confunda una propiedad meramente concomitante con una definitoria. Sólo la multiplicidad y variedad de objetos indicados puede reducir el margen de error.

El último método de definición es el *contextual*. En este caso se comunica el significado de una palabra incluyéndola en un contexto característico, de tal modo que la comprensión del conjunto de la frase o párrafo permita detectar el significado de la palabra. Por ejemplo: "en el accidente de tránsito en que murió el anciano, el conductor del vehículo no obró con *dolo* sino con imprudencia, pues al parecer no tenía ningún motivo para querer matar a la víctima". El significado del término *dolo*, como intención de un acto jurídico, surge implícitamente del contexto.

c) *Las oraciones y las proposiciones*

Hasta ahora hemos hablado sólo de las palabras. Pero las palabras cumplen su papel de comunicar ideas, no aisladamente, sino formando parte de oraciones.

Las oraciones son conjuntos de palabras ordenadas según ciertas leyes gramaticales (como la que dispone la necesidad de un verbo para constituir una oración).

Las oraciones pueden usarse, como vimos en el segundo capítulo, con fines muy diversos: para informar acerca de algo, para motivar ciertas conductas, para pedir información, para expresar un sentimiento, etcétera. Tales son los que se suelen denominar *usos del lenguaje*, o en general, *fuerza de las oraciones*.

Hay que distinguir la oración como entidad gramatical, de lo que la oración significa, que puede estar expresado también por otras oraciones o hasta por medios no lingüísticos.

Cuando una oración está usada con el fin de describir algo, su significado suele designarse con el nombre de *proposición* (aunque hay muchas discusiones filosóficas sobre la naturaleza

de las proposiciones). Es de las proposiciones, y no de las oraciones, de las que se predica verdad o falsedad, como lo muestra el hecho de que no cambia el valor de verdad aun cuando se usen diferentes oraciones, si ellas tienen el mismo significado (por ejemplo, no puede ser verdadero lo expresado por la frase: "Juan está a la izquierda de Pedro" y falso lo afirmado por la oración: "Pedro está a la derecha de Juan").

Las proposiciones o enunciados se relacionan con los estados de cosas, así como el significado de las palabras se relaciona con las cosas mismas que denotan.

Hay dos clases de proposiciones según sea el procedimiento que se utilice para determinar su verdad o falsedad.

Las proposiciones *analíticas* son aquellas cuya verdad o falsedad se determina por el mero análisis semántico o sintáctico de la oración que la expresa y, en última instancia, por aplicación de las leyes lógicas. Por ejemplo, el enunciado: "los perros son mamíferos" es una proposición analítica, puesto que implica, según el significado de la palabra "perro", que ciertos mamíferos son mamíferos, lo cual resulta verdadero por la sola aplicación del principio de identidad. El enunciado: "Hoy es martes y no es martes", es también analítico, ya que su falsedad surge asimismo de la aplicación del principio de no contradicción (generalmente los filósofos no llaman "analíticos" a los juicios contradictorios, limitando esa denominación a los juicios lógicamente verdaderos).

Los enunciados analíticos, o son ellos mismos contradictorios o sus opuestos son contradicciones.

La verdad o falsedad de los enunciados analíticos es *necesaria*, puesto que se mantiene independientemente de cómo sea la realidad y se la detecta *a priori* de toda verificación empírica.

Hay acuerdo en que la mayoría por lo menos de los enunciados de las matemáticas y las proposiciones que simplemente analizan una definición presupuesta, son analíticos y necesarios.

Los enunciados analíticos no sirven para dar cuenta de la realidad, ya que son compatibles o incompatibles con todo mundo posible. La función de los enunciados analíticos verdaderos consiste en permitir pasar de ciertos enunciados no analíticos a otros también no analíticos. Así, por ejemplo, los enunciados analíticos " $2 + 2 = 4$ " y "las peras y las bananas son frutas", permiten pasar de los enunciados no analíticos "hoy compré dos

bananas" y "hoy compré dos peras" al enunciado no analítico "hoy compré cuatro frutas".

Los enunciados no analíticos se denominan *sintéticos*. Son aquellos cuya verdad o falsedad *no* se determina por el mero análisis del enunciado ni por la aplicación de leyes lógicas. Estos enunciados no son contradictorios ni su negación constituye una contradicción. Ejemplos como "la pipa está prendida", "hace frío", "los cuerpos caen en dirección al centro de la tierra", pertenecen a esta categoría de enunciados. Se coincide en que la mayor parte de las proposiciones de las ciencias empíricas son sintéticas.

Hay una antigua y compleja discusión filosófica acerca de cómo se determina la verdad de estas proposiciones, ya que no es suficiente el mero análisis semántico y lógico.

La concepción empirista sostiene que *todos* los enunciados sintéticos tienen una verdad *contingente*, ya que depende de que algo ocurra o no ocurra en la realidad, lo cual sólo puede establecerse *a posteriori* de una adecuada verificación empírica (experiencia). Los enunciados son para esta concepción o bien analíticos y necesarios o bien sintéticos y contingentes.

En cambio, el racionalismo filosófico, cuyo exponente más lúcido fue Kant, defiende la tesis de que *algunos* enunciados sintéticos tienen una verdad *necesaria*, que no depende de los accidentes que puedan darse o no darse en la realidad y que se conoce *a priori* de toda experiencia sensible; por ejemplo, por intuición. Además de los de las matemáticas, un enunciado del cual se suele sostener que es sintético y necesario a la vez es el principio según el cual todo acontecimiento tiene una causa (llamado "principio de causalidad").

Actualmente, por la influencia de pensadores como W. O. Quine, se tiende a insistir menos en la distinción entre enunciados analíticos y sintéticos. Se sugiere que lo que se somete a la contrastación empírica es *todo un cuerpo de enunciados* y que sólo podemos distinguir entre aquellos enunciados del sistema que estamos más dispuestos a abandonar para evitar que el sistema resulte refutado por la experiencia —estos serían los enunciados que se suelen considerar sintéticos— y los enunciados que son más centrales al sistema porque estamos menos proclives a cambiarlos ante pruebas empíricas que contradicen al sistema —estos serían los enunciados que suelen verse como analíticos.

3. Los problemas de interpretación del lenguaje jurídico

El significado de las oraciones está determinado por el significado de las palabras que la integran y por el ordenamiento sintáctico de ellas. En muchas ocasiones las palabras usadas en una oración plantean problemas en cuanto a la determinación de su significado, y en otras el vínculo sintáctico entre los términos de la oración da lugar a equívocos.

De ello se infiere que muchas veces no es sencillo determinar qué proposición corresponde a una oración del lenguaje.

La dificultad no siempre se debe a que quien formuló la oración no hubiera querido comunicar una idea precisa, sino a que el lenguaje natural, al que hay que recurrir para comunicarse, padece de ciertos defectos endémicos que dificultan la transmisión clara del mensaje. Sin embargo, puede ocurrir también que el uso de un lenguaje impreciso para exponer nuestro pensamiento afecte a este mismo, de modo que, en muchas ocasiones, la idea que se desee transmitir no tenga más profundidad que el significado de las expresiones lingüísticas utilizadas.

Cuando se tiene a mano a quien ha formulado una oración vaga o equívoca, cabe obtener de él una especificación del significado de aquélla, preguntándole acerca de su intención. Es obvio que no siempre se dará esa oportunidad, sobre todo cuando se trate de un texto escrito; por lo cual en esos casos no habrá más remedio que tomar en cuenta elementos distintos de las aclaraciones mismas del autor, para especificar el significado de una oración que, de acuerdo con los usos lingüísticos vigentes, es imprecisa, vaga o ambigua.

El contexto lingüístico en el que la oración aparece (las frases que se dicen antes o después) y la situación fáctica en que se la formula (el lugar, el momento, etc.), son a veces datos relevantes para determinar bien el significado de una oración.

Alf Ross señala dos tendencias interpretativas diferentes que se pueden adoptar ante un texto lingüístico. La primera está constituida por el hecho de centrar la preocupación en la intención que tuvo el que formuló la oración; es ésta una interpretación *subjetiva*. La otra se preocupa primordialmente no por lo que quiso o no quiso decir el autor del texto, sino por lo que efectivamente dijo, según el significado que realmente poseen sus palabras en el lenguaje ordinario; se trata, entonces, de una interpretación

objetiva (aunque esta calificación no excluye que pueda tener también un grado considerable de arbitrariedad).

Existe la tendencia a interpretar objetivamente, o sea con independencia de la supuesta intención del autor, las obras artísticas y científicas. También suele haber casos del lenguaje coloquial en los cuales estamos interesados sólo en determinar cómo podrá entender la gente lo que alguien dijo, cualquiera que hubiere sido la intención del hablante, como, por ejemplo, cuando alguien hace públicamente una referencia dudosa respecto de nosotros. Como ya hemos dicho, también a propósito del lenguaje legal predomina la tendencia interpretativa objetiva.

Los problemas de interpretación de las oraciones lingüísticas se extienden también, naturalmente, a las oraciones mediante las cuales se formulan las normas jurídicas, aunque, como veremos en el capítulo próximo, no siempre lo reconocen así los juristas.

En derecho, el tener dudas interpretativas acerca del significado de un texto legal supone una falta de certeza acerca de la identificación de la norma contenida en ese texto; o, lo que es lo mismo, implica una indeterminación de las soluciones normativas que el orden jurídico ha estipulado para ciertos casos.

En lo que sigue expondremos algunos de los problemas de interpretación lingüística más notorios, y mostraremos cómo ellos se reflejan en algunos textos correspondientes al derecho argentino.

a) Ambigüedades

Una oración puede expresar más de una proposición. Puede ocurrir así porque alguna de las palabras que integran la oración tiene más de un significado, o porque la oración tiene una equivocidad sintáctica.

La ambigüedad semántica de algunas palabras (como, por ejemplo, “cabo”, “radio”, “prenda”, “mano”, etc.), es un hecho conocido por todos. Si se dice “el cabo de Hornos es muy frío”, se puede dudar si se alude al clima de una determinada región austral o a la falta de sensibilidad de un militar que se apellida “de Hornos”.

Hay casos de ambigüedad semántica que no constituyen una mera homonimia accidental, sino que dan lugar a mayores equívocos, debido a que los varios significados de la palabra tienen

una estrecha relación entre sí. Así ocurre con la llamada “ambigüedad de proceso-producto”, que se da cuando uno de los significados de la palabra se refiere a una actividad o proceso, y el otro al producto o resultado de esa actividad o proceso. Es lo que acaece con palabras como “trabajo”, “ciencia”, “construcción”, “pintura”. Si alguien dice “me encanta la pintura”, puede dudarse de si lo que le gusta es pintar él o contemplar cuadros.

También se da lugar a ambigüedades equívocas cuando una expresión tiene un significado vulgar relacionado con su uso científico, pero diferente de él. Eso ocurre con términos como “sal” y “alcohol”, que son usados por la gente común con una denotación más restringida que aquella en que los usan los químicos.

La ambigüedad semántica se origina muchas veces en un uso metafórico de una palabra, pero que con el tiempo va creando un significado independiente del original. Así ocurrió seguramente con el término “arteria”, aplicado a las calles de una ciudad; con la palabra “rama”, cuando con ella se designa alguna de las divisiones de una ciencia, etcétera.

Los siguientes textos constituyen ejemplos de ambigüedad semántica en nuestro derecho positivo.

— El art. 2º de la Constitución Nacional declara: “*El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano*”. La expresión “sostiene”, utilizada en la redacción de esta norma, adolece de cierta ambigüedad. Una interpretación le asigna el significado de “profesa”, otorgando a la norma el sentido de que el gobierno federal considera verdadera la religión católica; en cambio, otra interpretación, defendida por Joaquín V. González sobre la base de lo discutido por los Constituyentes, atribuye a la palabra *sostiene* el significado de “mantiene”, “apoya”, etc., concluyendo que la norma sólo establece que el gobierno debe atender económicamente al culto católico.

— En su redacción original, el art. 186, inc. 3º, del Cód. Penal, reprimía en forma agravada el causar un incendio, explosión o inundación, cuando “...hubiera peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería”. Como decía Soler, la expresión *arsenal* tiene en castellano dos sentidos: a) lugar donde se fabrican y reparan embarcaciones, y b) depósito de armas y pertrechos de guerra. Soler se inclinaba por la segunda alternativa, fundándose en que el primer significado estaba ya cubierto con la palabra “astillero”; sin embargo, aun siendo ese un buen argumento, no era del todo concluyente, ya que muchas veces las leyes emplean sinónimos parciales para abarcar el mayor conjunto de casos posibles.

— El art. 163, inc. 1º del Cód. Penal, en su anterior redacción, agravaba el hurto cuando, entre otras alternativas, fuera de *ganado*

mayor o menor. La expresión *ganado* había sido interpretada de dos modos diferentes. Jofré sostenía que, al igual que “rebaño”, es un nombre colectivo, que alude a una pluralidad de animales, de modo que quien se apoderase de una sola vaca no cometería hurto agravado; en cambio, Soler propugnaba la opinión contraria, admitiendo que un solo y único animal de ciertas especies puede considerarse “ganado” (la ley habla ahora de “una o más cabezas de ganado”).

Como hemos dicho, también puede darse el caso de que una misma oración tenga varios significados a causa de eventuales equivocidades en la conexión sintáctica entre las palabras que la integran.

Por ejemplo, la conectiva “o” es ambigua, puesto que a veces se la puede interpretar con la función de una disyunción excluyente (de modo que el enunciado es verdadero sólo si se da una de las alternativas que menciona, pero no las restantes), o con el significado de una disyunción incluyente (con lo cual, el enunciado es verdadero, tanto si se dan algunas de las alternativas como si se dan todas ellas). Si se dice: “se permite viajar en el avión con un abrigo o un bolso de mano”, un viajero podría dudar si puede viajar con ambas cosas o sólo con una de ellas.

También suele dar lugar a ambigüedad sintáctica el ámbito en el cual rige una conectiva. Si en vez de lo anterior, un cartel dice: “se permite viajar en el avión con un abrigo o un bolso de mano y un paraguas”, el mismo perplejo pasajero podría vacilar sobre si el paraguas se puede agregar sólo al bolso de mano o si también se lo puede llevar junto con el abrigo.

Alf Ross señala un problema similar respecto de las frases de excepción o condición.

Si un testador dice: “Lego a Juancito mis mariposas y mi casa, siempre que viva en ella”, puede dudarse si la condición rige también para el legado de las mariposas o si sólo se refiere al de la casa.

También los pronombres pueden dar lugar a equívocos sintácticos. Si un abogado dice a su cliente: “el juez puede decretar contra usted la prisión preventiva y el embargo de bienes; pero ello no obstante, se podrá apelar”, el asustado consultante acaso se vaya con la duda de si la apelación se extenderá a la prisión preventiva o sólo se la permitirá en el caso de embargo.

Desde luego que el ámbito en el cual rige un adjetivo o una frase adjetival también puede dar lugar a equívocos. Si digo: “sólo voy a invitar a mi casamiento a los parientes y a los amigos

que me hagan un regalo generoso", mis parientes podrán dudar de si la calificación los alcanza o sólo se refiere a mis amigos.

Veamos ahora algunos ejemplos de ambigüedad sintáctica en nuestro derecho:

— El art. 179, 2ª parte, del Cód. Penal, dice: "*Será reprimido con... el que durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles.*"

Apenas fue sancionada esta norma, los juristas observaron críticamente que no se había previsto en forma explícita el caso de la venta de los bienes, o sea el procedimiento más frecuente con que los deudores suelen defraudar a sus acreedores.

Se ha propuesto, por el doctor Enrique Bacigalupo, que se aproveche una supuesta ambigüedad semántica de la expresión *hacer desaparecer*, que en ciertos contextos se usa para denotar también la enajenación de bienes. Sin embargo, el doctor Enrique Paixao ha replicado, con razón, que tal uso de la expresión es meramente figurado y que se limita a la jerga de los abogados y martilleros.

Quizá la solución aparezca si se advierte que el artículo tiene una ambigüedad sintáctica en la frase "*o fraudulentamente disminuir su valor*", pudiendo ser entendido como si se refiriese al valor de los bienes, o bien al valor del patrimonio en su conjunto. Con esta segunda interpretación, la venta de bienes estaría comprendida en la figura, ya que constituye una forma nítida de disminuir el valor del patrimonio.

— El art. 186, inc. 3º, del Cód. Penal, en su redacción original que ya hemos citado para ilustrar un caso de ambigüedad semántica, presentaba también una equivocidad sintáctica cuando, al enumerar los bienes cuyo incendio, explosión o inundación motivaba un agravamiento de la pena, después de mencionar los arsenales y astilleros, decía "*fábrica de pólvora o pirotecnia militar*".

Se había planteado la duda acerca de si el adjetivo "*militar*" calificaba sólo a las fábricas de pirotecnia o también a las de pólvora. Soler ponía énfasis en que debía interpretarse que el adjetivo no se refería a las fábricas de pólvora, puesto que existe la misma razón, constituida por el extraordinario peligro producido, para agravar un incendio o explosión tanto cuando se lo hace en una fábrica de pólvora que sea militar como cuando se lo provoca en otra que no lo sea.

— El art. 184, inc. 5º, del Cód. Penal, antes de la reforma por la ley 21.338, agravaba el delito de daño cuando se daban estas circunstancias: "*Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público...*".

Se ha planteado el interrogante acerca de si la exigencia de que fueran de uso público se refería a todos los bienes enumerados, o sólo

a los mencionados después de la disyunción. Soler se inclinaba por la segunda alternativa, por no haber motivos para no proteger de igual modo los archivos, registros y bibliotecas según fueran privados o públicos.

— El art. 163, inc. 1º, del Cód. Penal, ya mencionado, agrava el delito de daño “cuando el hurto fuere de una o más cabezas de ganado mayor o menor o de productos separados del suelo o de máquinas o instrumentos de trabajo, *dejados en el campo*.” Se podría dudar acerca de qué referencia tiene la frase “*dejados en el campo*”, o sea si se refiere, por ejemplo, a todos los elementos enumerados, como dice Soler, o si, por el contrario abarca sólo las máquinas o instrumentos de trabajo.

— El art. 2614 del Cód. Civil establece: “Los propietarios de bienes raíces no pueden constituir sobre ellos derechos enfitéuticos, ni de superficie, ni imponerles censos, ni rentas *que se extiendan a mayor término que el de cinco años...*”

Se ha discutido si la expresión “*que se extiendan a mayor término que el de cinco años*” se refiere a todos los derechos enumerados, como piensa Machado; si abarca sólo las rentas, como lo entiende Llerena; o si comprende únicamente los censos y las rentas, como sostiene Segovia.

b) *Imprecisiones*

La proposición expresada por una oración puede ser vaga, a causa de la imprecisión del significado de algunas de las palabras que forman parte de la oración.

El caso más común de vaguedad es el ejemplificado por el significado de palabras como “alto”, “rojo”, “pesado”, “inteligente”, “lejos”, “rico”, etcétera.

Estas palabras hacen referencia a una propiedad que se da en la realidad en grados diferentes, sin que el significado del término incluya un límite cuantitativo para la aplicación de él. Como muchas veces se ha dicho, respecto de las palabras vagas la realidad puede clasificarse en tres zonas: una de claridad, constituida por los hechos denotados con certeza por el término (por ejemplo, las personas que miden más de 1,80 m, en relación a la palabra “alto”); otra de obscuridad, formada por hechos respecto de los cuales se sabe con seguridad que la palabra no se aplica (por ejemplo, las personas que miden menos de 1,65 m, en relación a “alto”), y la última, de penumbra, constituida por casos a propósito de los cuales dudamos en aplicar o no el término (las personas que miden entre 1,70 y 1,80 m, respecto de “alto”).

Pero la vaguedad debida a propiedades que se dan como un *continuo*, no constituye el único caso posible, ni el más complejo, de imprecisión semántica.

Resulta que no siempre la designación de una palabra está constituida por propiedades que sean, cada una de ellas, aisladamente considerada, necesarias para el uso del término. A veces algunas de las propiedades relevantes para el uso de cierta palabra pueden estar ausentes y, sin embargo, usarse lo mismo tal término, dada la presencia de otras propiedades relevantes (esto se suele llamar *vaguedad combinatoria*).

Recurriendo a un ejemplo de Wittgstein, la palabra "juego" no designa ninguna propiedad que sea por sí sola necesaria para su empleo, como lo muestra el hecho de que las actividades denotadas por ella —por ejemplo, el ajedrez, la rayuela, el solitario, la lotería, el boxeo, la ruleta, el fútbol, etc.—, no parecen tener ningún elemento en común (la diversión no se da en la lotería, el azar no se da en el ajedrez), sino sólo ciertas propiedades entrecruzadas entre los miembros de la clase, en forma análoga a como se entrecruzan a veces los rasgos característicos de una familia.

En estos términos (también son ejemplos de ellos las palabras "oro", "casa", "pizarrón", "ciencia", etc.), hay ciertas combinaciones de propiedades que nos dan la seguridad de que la palabra es aplicable; otras, ante las cuales nos abstendríamos de usarla y, por último, otras, frente a las cuales dudamos en aplicar o no la palabra sin tener criterios definidos para resolver la cuestión en un sentido o en otro. Por ejemplo, ¿es un juego la ruleta rusa?, ¿lo es la especulación en la bolsa?, ¿se puede catalogar como juego la práctica de tiro al blanco?

Una especie de vaguedad más intensa todavía que las que acabamos de mencionar, está constituida por palabras respecto de las cuales no sólo no hay propiedades que sean aisladamente indispensables para su aplicación, sino que hasta es imposible dar una lista acabada y conclusa de propiedades suficientes para el uso del término, puesto que siempre queda abierta la posibilidad de aparición de nuevas características, no consideradas en la designación, que autoricen el empleo de la palabra.

Según Genaro Carrió, el adjetivo "arbitraria", que la Corte Suprema emplea para censurar algunas sentencias judiciales, constituye un caso de esta especie de vaguedad, puesto que, además de las situaciones centrales en que aquel calificativo es usado por la Corte, queda abierta la puerta para la aparición de nuevas

circunstancias de momento imprevisibles pero ante las cuales podría resultar apropiado calificar de arbitraria a una sentencia.

Probablemente adolezcan de este mismo modo de vaguedad algunas expresiones que denotan estados psicológicos, como “neurótico”, “intención”, etcétera.

Una última modalidad de imprecisión semántica, la llamada “*textura abierta*”, es por demás interesante, ya que constituye un vicio potencial que afecta a todas las palabras de los lenguajes naturales.

Resulta que aun las palabras más precisas pueden suscitar dudas acerca de su aplicabilidad ante circunstancias insólitas e imprevistas. Siguiendo el modelo de otro ejemplo propuesto por Carrió, imaginemos que después de algún esfuerzo consigamos definir informativamente la palabra “lapicera” como un objeto que sirve para escribir con tinta sobre una superficie apta. Provisos de esta definición, nos hallamos, al parecer, en condiciones de enfrentar al mundo, distinguiendo los objetos que son lapiceras de los que no lo sean. Pero ¿qué ocurrirá si nos encontramos con un objeto que posee las propiedades que, según nuestra definición, son suficientes para designarlo con la expresión “lapicera”, pero tiene además la propiedad concomitante de escribir en inglés lo que quisiéramos expresar en castellano, o la de escribir un poema místico cuando intentáramos redactar un manual de introducción al derecho, o la de negarse a escribir cuando pretendemos garrapear una mala palabra? Seguramente, ante esas extrañas circunstancias, revocaríamos la primitiva clasificación del objeto en cuestión como lapicera, asignándole probablemente otro nombre *ad hoc*, más apropiado.

Este ejemplo muestra que nunca podemos darnos por satisfechos de haber encontrado un conjunto de propiedades que sea suficiente para el uso de una expresión, toda vez que deberíamos añadir a ese conjunto la exigencia de que no se den ciertas circunstancias insólitas, pero que teóricamente podrían darse. Como es imposible prever todas las propiedades extrañas que puedan presentarse, la lista de las circunstancias que *no* deben darse para que sea aplicable una palabra, tiene que ser abierta: debe concluir con un “etcétera”, y no con un punto final.

Si la designación primitiva de un término es *A*, *B* y *C* (en la que las letras equivalen a ciertas propiedades), después de considerar la textura abierta a la cual está sujeto, debemos represen-

tra tal designación, por ejemplo, como *A, B, C* y *-D, -E, -F*, etcétera.

Se podrían dar innumerables ejemplos de vaguedad efectiva en el lenguaje de la ley. En lo que sigue ofreceremos sólo unos pocos de ellos:

— El art. 184, inc. 2º, del Cód. Penal, en su redacción previa a la ley 21.338, agravaba el delito de daño cuando consistiera en: “*Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos*”.

Obviamente, un perro y un gato son animales domésticos y no lo son ni un león ni una jirafa. Sin embargo, hay animales ante los cuales uno podría tener justificadas dudas sobre su clasificación. Por ejemplo, ¿son animales domésticos las moscas amaestradas que un excéntrico guarda en una caja? ¿Lo es un sapo con el que un niño se divierte?

— El art. 85 del Cód. Penal, como hemos visto, castiga a quien causa un aborto.

Todos estamos de acuerdo en que matar un feto de cinco meses es aborto. Pero se presentan dudas acerca de si puede clasificarse, por ejemplo, como *aborto*, el impedir, usando un medio intrauterino generalmente considerado anticonceptivo, que un huevo ya fecundado se implante en el útero. También puede ser dudoso si constituye aborto, o si es más bien homicidio, el matar al feto cuando ya están produciéndose las contracciones que inician el proceso de su expulsión natural.

— Cuando el art. 81, inc. 1º, del Cód. Penal atenúa la pena al que matare a otro encontrándose en estado de “*emoción violenta*”, es obvio que se da origen a una magnífica penumbra constituida por casos en los cuales vacilamos acerca de si la emoción de un sujeto tuvo o no el grado suficiente para poderse la calificar de *violenta*.

— El art. 34, inc. 1º, del Cód. Penal exime de pena cuando el autor de un delito padezca de insuficiencia de facultades mentales o de alteración morbosa de ellas. ¿Cuál es el grado de disminución intelectual que exime de pena y cuál la medida de la alteración mental que la convierte en morbosa? Esta duda se ha planteado en la jurisprudencia sobre todo en relación a ciertas psicopatías.

— El art. 141 del Cód. Penal reprime la acción de privar ilegalmente a otro de su libertad personal. ¿Comete esa acción el colectivo que a sabiendas de que un pasajero desea bajar en una parada no detiene su vehículo hasta la siguiente?

— El art. 1198, párr. 2º, del Cód. Civil dispone: “*En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato*”. ¿Cuándo un acontecimiento deja de ser

lo suficientemente común y corriente para ser extraordinario? y ¿cuándo una mayor onerosidad en la prestación es *excesiva*?

En cuanto a la vaguedad potencial, o textura abierta, no tiene sentido particularizar algunos casos de normas que la padezcan, puesto que podría oscurecer el hecho de que *todas* las normas tienen en forma latente ese defecto. En cambio, quizá sea útil proponer algunos ejemplos de situaciones imaginarias que harían dudar acerca de la aplicación hasta de las normas más precisas.

— Imaginemos el caso de un científico que haya inventado una técnica para resucitar a los muertos, siempre que no haya transcurrido más de un día desde que hayan fallecido. Como no tiene a su alcance material humano suficiente para sus experimentos, recurre a su esposa, quien de buen grado, dada su confianza ciega en el marido, se presta a la experiencia. Pues bien, utilizando un gas letal el científico mata a su mujer; pero, después de varias horas de infructuosas tentativas, le devuelve la vida en las mismas condiciones que antes. Puesto que el médico cometió la acción de matar a su esposa, ¿lo condenaríamos en aplicación del art. 80 del Cód. Penal, que reprime con prisión perpetua el homicidio cometido contra el cónyuge?

— Supongamos este otro caso: se descubre la existencia de una tribu en la selva del Chaco en la cual, desde tiempo inmemorial, existe la costumbre, apoyada en creencias religiosas, de que las mujeres deben oponer tenaz resistencia al contacto sexual con los varones, si bien no es repudiable que estos segundos intenten vencer aquella resistencia. ¿Condenaría el juez, de acuerdo con el art. 119, inc. 3º, del Cód. Penal, a todos los hombres de aquella tribu que hubieran tenido acceso carnal venciendo la resistencia física de las mujeres?

— El inc. 2º del art. 215 del Cód. Penal reprime con prisión perpetua al que comete el delito de inducir o decidir a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República. Se trata obviamente de un delito atroz, ¿pero qué pasaría si en el país ocurriera algo similar a lo de la Alemania nazi y muchos argentinos no vieran otro remedio que unirse a una potencia extranjera para derrocar a un gobierno que hubiera asesinado a gran parte de la población? Una vez caído el régimen, ¿se aplicaría a tales ciudadanos la mencionada norma?

— Como vimos, el delito de aborto consiste en matar un feto. En un caso reciente se practicó la fecundación y gestación *in vitro*, uniendo en un laboratorio un espermatozoide con un óvulo femenino y conservando el huevo así fecundado por un tiempo en un medio apto, hasta que fue implantado en el útero materno. Supongamos que un científico, atormentado por dudas religiosas, decide, en un caso semejante, cortar la electricidad que permite la temperatura adecuada del medio y el feto muere. ¿Condenaríamos al científico por aborto?

c) *La carga emotiva del lenguaje*

Hay algunas palabras que sólo sirven para expresar emociones o para provocarlas en los demás. Expresiones como “¡ay!”, “¡hurra!”, “¡viva!”, “¡bravo!”, no tienen significado descriptivo, sino que se limitan a ser vehículos de emociones.

Otras palabras hacen referencia a objetos o hechos, pero además expresan ciertas actitudes emocionales que ellos provocan en el que las usa. Tal es el caso de las llamadas “malas palabras”, que llevan una carga emotiva de la cual carecen otros términos con idéntico significado descriptivo, pero que se usan en contextos emotivamente neutros. Asimismo, tienen un fuerte significado emotivo, además del cognoscitivo, palabras como “democracia”, “dictadura”, “idiota”, “derecho”, “crimen”, etcétera.

La carga emotiva de las expresiones lingüísticas perjudica su significado cognoscitivo, favoreciendo su vaguedad, puesto que si una palabra funciona como una condecoración o como un estigma, la gente va manipulando arbitrariamente su significado para aplicarlo a los fenómenos que acepta o repudia. De este modo, las definiciones que se suelen dar de las palabras con carga emotiva son “persuasivas”, según la terminología de Stevenson, puesto que están motivadas por el propósito de orientar las emociones, favorables o desfavorables, que provoca en los oyentes el empleo de ciertas palabras, hacia objetos que se quiere encomiar o desprestigiar.

No es muy usual que en un sistema jurídico moderno se usen palabras con carga emotiva. Los siguientes constituyen algunos de los casos excepcionales que cabe encontrar en nuestro derecho.

— El gobierno militar que se instaló en 1966 se apartó de las costumbres de los anteriores gobiernos *de facto* de denominar “decretos leyes” a sus normas generales, para indicar que tenía un origen análogo al de los decretos, pero con el contenido y el alcance de leyes del Parlamento. El régimen de que hablamos rompió con aquella costumbre lingüística, llamando “leyes” a sus normas, con el evidente propósito de aprovecharse de la favorable carga emotiva de la palabra “ley” en prestigio de sus prescripciones.

— El art. 128 del Cód. Penal reprime a quien publicare, fabricare, etc., libros, objetos, etc., *obscenos*. La expresión subrayada adolece de una fuerte vaguedad, que está provocada, en gran parte, por su significado emotivo desfavorable, lo cual hace que se la use muy libremente, según las actitudes que cada uno sustente hacia ciertas obras u objetos.

d) La fuerza de las oraciones

Ya hemos visto que el lenguaje puede usarse con distintos fines. A veces se lo usa para informar de algo que ha ocurrido, otras veces para requerir una información; también se lo usa para prescribir una cierta acción o para realizarla, si es que la tal acción exige la formulación de ciertas palabras (para ver con más detalles estas funciones del lenguaje, puede consultarse el capítulo II).

Habrán veces en que se planteen dudas acerca, no del significado de una oración, sino de su fuerza. El que la escucha o la lee puede dudar, por ejemplo, de si la oración expresa una aserción, una pregunta, una orden, un deseo, etcétera. Algunas personas tienen el suficiente tacto para formular la orden de que se cierre una ventana diciendo: "hace un poco de frío en la habitación", pudiendo ocurrir que alguien la interprete como mera aserción y conteste, por lo tanto: "es verdad", quedándose quieto. Lo mismo, si alguien dice: "usted le podría dar una paliza a Fulano si lo desea", esta oración podría interpretarse, ya como aserción acerca de la capacidad física del otro, ya como sugerencia o permiso para que castigue al tercero.

En el derecho no son muy frecuentes los casos de dudas acerca de la fuerza de las oraciones legales, puesto que, como hemos visto, generalmente expresan ellas prescripciones. Dejando de lado algunos ejemplos más complejos, como podrían ser los que menciona Carrió, por ejemplo los que provocan dudas interpretativas acerca de si una norma impone una obligación o una carga, vamos a ilustrar la cuestión con el siguiente problema:

— El Código Penal argentino, como casi todos los códigos contemporáneos, está dividido en distintas secciones, cada una de las cuales lleva un título o subtítulo. Por ejemplo: "Delitos contra las personas", "Delitos contra la vida", "Delitos contra la honestidad", "Delitos contra la fe pública".

Los mencionados títulos indican el bien jurídico que las normas encabezadas por ellos tienden a proteger.

Los juristas discuten si esos títulos son obligatorios para la interpretación de las normas penales o si tienen un valor meramente clasificatorio. Por ejemplo, si el hecho de que la norma que reprime la violación se encuentra bajo el título "delitos contra la honestidad" y no entre los delitos que el legislador ha clasificado como atentatorios contra la libertad, tiene incidencia o no, pongamos por caso, en la

determinación de cuáles serán los posibles sujetos pasivos del delito (¿es punible la violación de una prostituta?).

En definitiva, la duda que se plantea se refiere a la fuerza de la oración implícita en el título. Cuando el legislador escribe “delitos contra la honestidad”, ¿formula una aserción, que se podría expresar con la frase: “los delitos que a continuación se tipifican afectan predominantemente a la honestidad”, o sanciona una prescripción, expresable como “interpretense las normas siguientes en el sentido de que su finalidad es proteger la honestidad”?

e) *Dificultades en la promulgación de las normas*

En muchas ocasiones cabe dudar acerca del mensaje que alguien quiso transmitir porque se sospecha que no eligió la frase adecuada para expresarlo, o porque no se sabe bien qué oración formuló (porque, por ejemplo, no hay constancia cierta de ella, sino sólo distintas versiones indirectas).

En el caso de las normas legisladas esto ocurre con alguna frecuencia.

Hay veces en que resulta notorio que el legislador ha querido decir algo radicalmente diferente de lo que dijo, habiendo caído en un simple *lapsus* en el uso de ciertas palabras o notaciones sintácticas. En esos casos se puede disentir acerca de la necesidad de superar la letra de la ley o de someterse a lo que está escrito.

Otras veces ocurre que la edición oficial ha reproducido mal el texto legal o hay diferencias entre diversas ediciones de un mismo texto legal.

Veamos sólo tres ejemplos:

— El art. 2161 del Cód. Civil dice: “Si los derechos hereditarios fueren *legítimos*, o estuviereñ cedidos como dudosos, el cedente no responde por la evicción”.

A pesar de que en las ediciones oficiales del Código Civil de 1870 y 1883 figura en este artículo la palabra *legítimos*, hay acuerdo entre los juristas en que lo que el legislador quiso decir debió de haberse expresado con la palabra *litigiosos*, y que el texto, tal como quedó redactado, carece de sentido.

— El art. 521 del Cód. Civil, antes de la reforma de la ley 17.711, decía, según la edición del proyecto de Vélez Sársfield y la edición oficial de 1882, lo siguiente: “*Aun cuando la inejecución de la obligación resulte del dolo del deudor, los daños e intereses comprenderán sólo los que han sido ocasionados por él y los que el acreedor ha sufrido en sus otros bienes*”.

En cambio, en las ediciones oficiales de 1883, 1889, 1900 y 1904,

el texto es notablemente diferente, pues dice “y *no* los que el acreedor ha sufrido en los otros bienes”.

Según Segovia, Machado, Llerena, etc., el texto que debía prevalecer es aquel en el cual aparecía la negación. En cambio, Salvat, Bibiloni Lafaille, etc., se inclinaban por que el artículo debía ser entendido sin el *no*.

— El art. 187 del Código Penal reprimía, en su redacción original, al que causare estrago por medio de, entre otras cosas, “la inundación de una mina”. Pero la ley de fe de erratas (nº 11.221) agregó una coma entre las palabras “inundación” y “de una mina”, resultando ahora que es punible el que causare estrago por medio “de una mina” (lo que, según dice Soler, criticando esta reforma, “tuvo el efecto insospechado de transformar una *mina* en una bomba”).

4. Los defectos lógicos de los sistemas jurídicos

Los problemas de interpretación que hemos estudiado hasta ahora presuponen dudas acerca de las consecuencias lógicas que pueden inferirse de ciertos textos jurídicos, quedando sin determinar la calificación normativa que ellos estipulan para determinados casos.

Estos problemas deben distinguirse de otros que no consisten en dificultades para derivar consecuencias de normas jurídicas, sino que, por el contrario, aparecen una vez que tales consecuencias han sido deducidas.

Sin embargo, ambos grupos de problemas tienen en común el impedir que pueda justificarse la solución de un caso concreto sobre la base exclusiva de un sistema jurídico. Constituyen deficiencias que el derecho a veces presenta cuando se lo aplica para calificar normativamente ciertas conductas.

Los defectos que analizaremos a continuación pueden calificarse de “lógicos” en sentido sumamente genérico. Todos ellos suponen la frustración de ciertos ideales racionales que debe satisfacer un sistema normativo e inclusive cualquier sistema de enunciados. Independientemente de actitudes valorativas, se pretende que los sistemas de normas sean coherentes, completos, económicos y operativos.

a) *Las contradicciones entre normas jurídicas*

Hay una contradicción entre normas cuando dos normas imputan al mismo caso soluciones incompatibles. En la formu-

lación de Alchourrón y Bulygin, un sistema normativo es inconsistente cuando correlaciona un caso con dos o más soluciones y lo hace de tal modo, que la conjunción de esas soluciones constituye una contradicción normativa.

La primera condición, pues, para que haya inconsistencia normativa, es que dos o más normas se refieran al mismo caso, que tengan el mismo ámbito de aplicabilidad. La segunda condición, es que los normas imputen a ese caso soluciones lógicamente incompatibles.

Como dicen Alchourrón y Bulygin, qué soluciones normativas son o no incompatibles dependerá de la lógica deóntica que se presuponga.

Sin embargo, en general se acepta que la prohibición de una acción es lógicamente incompatible con su permisión y con su facultamiento (o sea, la permisión tanto de la acción en cuestión como de su opuesta); que la obligatoriedad es incompatible con el facultamiento de la acción y con su prohibición, y que la permisión de una conducta es compatible con su facultamiento y con su obligatoriedad. Estas relaciones las mostraremos en el siguiente cuadro, en el cual las letras "F", "P", "Ph" y "O" indican, respectivamente, los operadores facultativo, permitido, prohibido y obligatorio, y los símbolos "—" "/" la compatibilidad y la incompatibilidad lógica, respectivamente.

F — P
F / Ph
F / O
P — O
P / Ph
Ph / O

Hay veces en que la inconsistencia entre dos normas jurídicas no aparece clara y se necesita de un análisis cuidadoso para mostrarla. Pongamos sólo este ejemplo: supongamos que haya una norma penal que establece: "si alguien injuria a otro, debe aplicársele *dos* años de prisión", y que haya otra que estipula "si alguien injuria a otro, debe aplicársele *un* año de prisión". En principio no parece que hubiera contradicción entre las dos normas, sino más bien una redundancia, puesto que ambas normas estipulan la obligatoriedad de dos acciones que se encuentran en una relación de más o menos entre sí, como en el caso de una madre que ordenara a su hijo que tomara la sopa mientras que el padre le mandara que tomara la sopa y comiera la tortilla. Aparentemente, obedeciendo a la norma que estipula aplicar dos años de cárcel al que injuria, se satisface también la nor-

ma que ordena que se le aplique un año de prisión. Sin embargo, las normas penales deben interpretarse en conjunción con el art. 18 de la Const. Nacional, que consagra el principio *nulla poena, sine lege*, en el sentido de que obligan a la aplicación de una cierta pena y, además, *prohiben* la aplicación de una pena mayor. De modo que las dos normas del ejemplo son contradictorias, puesto que la primera prohíbe implícitamente a los jueces aplicar, al que injuria, más de un año de prisión y la segunda los obliga, en cambio, a que lo hagan.

Hemos dicho que uno de los requisitos de la contradicción normativa es que ambas normas se refieran a *las mismas circunstancias fácticas*. Esto puede ocurrir, bien porque la descripción del caso que hace una norma es equivalente a la descripción que hace otra, bien porque una de las descripciones implica lógicamente a la otra, o bien porque, a pesar de ser ambas descripciones independientes, hay casos que, contingentemente, caen en ambas descripciones. Por ejemplo, en los casos que los penalistas clasifican como de “especialidad” (hurto y robo, homicidio y paricidio, etc.), hay una relación de implicación lógica entre las descripciones de ambas normas; en cambio, en los casos que la dogmática penal rotula como “concurso ideal” (por ejemplo, atentado a la autoridad y lesiones, violación y contagio venéreo, desacato a un funcionario y calumnias), las descripciones de las normas conflictivas son lógicamente independientes, pero no excluyentes, de modo que una misma acción puede caer en ambas descripciones.

Independientemente del tipo de relación que pueda haber entre las distintas descripciones de las normas cuyas soluciones son incompatibles, también es posible hacer una clasificación de acuerdo con el grado de superposición entre esas descripciones.

Alf Ross distingue, según ese criterio, tres clases de inconsistencias:

La inconsistencia *total-total*, que se da cuando los ámbitos de referencia de ambas normas se superponen totalmente: tales descripciones se podrían diagramar como dos círculos absolutamente superpuestos. Un ejemplo estaría constituido por dos normas, una de las cuales estipulara, por ejemplo, que la importación de tractores debe pagar un recargo aduanero y otra que estableciera que los tractores importados están exentos de recargos aduaneros.

La inconsistencia *total-parcial* se configura cuando el ámbito de referencia de una norma está incluido totalmente en el de otra, pero esta última comprende, además, casos adicionales. En este caso pueden diagramarse las referencias de ambas descripciones

como dos círculos concéntricos, uno de los cuales se hallara dentro del otro. Por ejemplo: una norma establece que la importación de vehículos sufrirá recargos aduaneros y otra exime de tales recargos a los tractores.

Por último, la inconsistencia *parcial-parcial* se da cuando las descripciones de dos normas con soluciones incompatibles se superponen parcialmente, pero ambas tienen además ámbitos de referencia autónomos. Se puede representar esta inconsistencia con dos círculos secantes. Un ejemplo en la línea de los anteriores podría estar configurado por dos normas, una de las cuales estableciera que los vehículos que se importan están sujetos a recargos aduaneros, y la otra estipulara que los instrumentos para la producción agrícola están exentos de ellos; los tractores están en el campo de conflicto de ambas normas, los autos sólo están comprendidos en la primera y los arados sólo se rigen por la segunda.

Los juristas y los jueces utilizan, como dice Alf Ross, varias reglas para resolver los problemas de contradicción normativa.

Elas están constituidas, sobre todo, por los principios llamados *lex superior*, *lex specialis* y *lex posterior*.

El principio *lex superior* indica que entre dos normas contradictorias de diversa jerarquía debe prevalecer la de nivel superior (por ejemplo, una norma constitucional tiene prioridad sobre una ley). La aplicación de este principio es esencial para que funcione la delegación del poder, pero no carece de excepciones. Todos conocemos casos de leyes evidentemente inconstitucionales o de sentencias ilegales cuya validez fue, sin embargo, mantenida por los tribunales superiores.

Lex posterior estipula que la norma posterior prevalece sobre la promulgada con anterioridad. Este principio también tiene una aplicación muy general —tanto que sin él no sería posible la derogación de las normas de un sistema— pero, sin embargo, reconoce también excepciones, sobre todo en algunos casos de conflicto con la *lex superior*.

El principio *lex specialis* prescribe que se dé preferencia a la norma específica que está en conflicto con una cuyo campo de referencia sea más general. Al igual que las anteriores, no siempre esta regla se observa, principalmente cuando la norma general sea superior o posterior respecto de la particular.

Muchos jueces y juristas pretenden que estos principios se aplican mecánicamente, como si las inconsistencias que ellos ayu

dan a solucionar nunca hubieran existido. Sin embargo, no puede otorgarse a estas reglas el carácter de leyes lógicas, puesto que su aplicación, como vimos, está sujeta a evaluaciones pragmáticas, que dan lugar a excepciones irregulares. Además, si bien hay cierta prelación entre estos principios —por ejemplo *lex superior* tiende a predominar sobre los restantes—, no hay reglas de segundo nivel para resolver mecánicamente los conflictos entre ellos (sobre todo entre *lex posterior* y *lex specialis*). Por último, hay muchos casos de normas contradictorias en los cuales estas reglas son inaplicables por tener las normas la misma jerarquía, haber sido dictadas simultáneamente (por ejemplo, integrando un mismo código) y tener el mismo grado de generalidad. (También son inaplicables algunas de estas reglas cuando las normas en conflicto no son reconocidas, como es el caso de los principios que menciona Dworkin y que vimos en el capítulo III, por derivar de cierto *origen*; los principios *lex superior* y *lex posterior* hacen referencia al origen de las normas.)

A continuación veremos algunos ejemplos de inconsistencia normativa que se da en el derecho positivo, dejando de lado los casos en que obviamente se aplican las reglas ya mencionadas.

—Nuestro Cód. Penal prevé en los arts. 89, 90 y 91 distintas penas para las lesiones simples, graves y gravísimas.

El art. 92 del Cód. Penal *grava* aquellas penas cuando las lesiones se produjeran a un pariente directo, con alevosía o ensañamiento, por precio, para consumir otro delito, etcétera.

A su vez el art. 93 del Cód. Penal *disminuye* las penas de los arts. 89, 90 y 91 cuando las lesiones fueren causadas en estado de emoción violenta.

Curiosamente, antes de la reforma por la ley 21.338, ocurría que el legislador no había previsto ninguna solución específica para aquellos casos de lesiones en los cuales concurrían *simultáneamente* algunas de las agravantes del art. 92 con la atenuante del art. 93, por ejemplo, cuando alguien lesionara a la esposa en estado de emoción violenta.

No se trataba de un caso de laguna normativa, puesto que el problema no radicaba en que no hubiera una solución para el caso, sino en que había varias soluciones lógicamente incompatibles. Se trataba de una inconsistencia parcial-parcial.

Pensemos en un caso de lesiones simples cometidas contra un familiar, con emoción violenta. Antes de la reforma mencionada, de acuerdo con el art. 89, correspondía la pena de un mes a un año; según el art. 92, de seis meses a dos años, y de acuerdo con el art. 93, una pena de quince días a seis meses. Supongamos que dejáramos de lado el art. 89, ateniéndonos a la *lex specialis*, de cualquier modo,

nos quedarían las normas contradictorias de los arts. 92 y 93, ninguna de las cuales es superior a la otra, ni posterior, ni más específica.

Esta cuestión fue discutida por la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital en el plenario "Britos" del 29 de julio de 1944. En ese fallo seis jueces se inclinaron por la aplicación atenuada del art. 93, uno por el encuadramiento de la agravada por el art. 92 y dos por la aplicación de las figuras simples, o sea, según el caso, por los arts. 89, 90 ó 91. En consecuencia, triunfó la tesis de la aplicación de la atenuante.

— Otro caso de inconsistencia parcial-parcial se da entre los arts. 156 y el 277 del Código Penal en conjunción con el art. 165 del Cód. de Procedimientos en lo Criminal de la Capital Federal.

El art. 156 del Cód. Penal reprime a quien teniendo noticia, por su oficio, empleo o profesión, etc., de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa; es decir que impone la obligación de guardar secreto profesional. El art. 277 reprime a quien dejare de comunicar a la autoridad las noticias que tuviera acerca de la comisión de un delito cuando estuviere obligado a hacerlo por su profesión o empleo. A su vez, el art. 165 del Cód. de Procedimiento en lo Criminal obliga a los médicos a denunciar en veinticuatro horas los atentados personales a raíz de los cuales hayan prestado los socorros de su profesión.

Supongamos el caso de un médico a quien viene a pedir asistencia una persona que ha sido herida en un asalto en el cual participó. De acuerdo con el art. 156 del Cód. Penal, el médico tiene la obligación de no denunciar el hecho; en cambio, teniendo en cuenta el art. 277 del Cód. Penal y el art. 165 del Cód. de Procedimiento en lo Criminal, el profesional tiene el deber de denunciarlo. Se trata de una situación de encerrona en la cual, en principio, cualquier actitud que adopte el médico será punible.

Aunque con algunas vacilaciones y excepciones, la jurisprudencia tiende a hacer prevalecer la obligación de guardar el secreto profesional sobre el deber de denunciar.

— El art. 2401 del Cód. Civil dice: "*Dos posesiones iguales y de la misma naturaleza, no pueden concurrir sobre la misma cosa*". A su vez el art. 2409 del mismo Código estipula: "*Dos o más personas pueden tomar en común la posesión de una cosa indivisible, y cada una de ellas adquiere la posesión de toda la cosa*".

Como se ve, una norma veda que dos personas tengan la posesión de una cosa con el mismo título, por ejemplo como propietarios, mientras que la otra permite la concurrencia de posesiones sobre toda la cosa.

A pesar de la inconsistencia casi literal, los autores hacen compatibles ambas normas, distinguiendo entre las relaciones que pueden tener los poseedores entre sí y con terceros. Respecto de los terceros, cada uno de los poseedores puede reclamar la posesión total de la cosa; en cambio, un poseedor no puede reclamar a su co-poseedor la totalidad de la posesión de ella.

— El art. 2387 del Cód. Civil establece: “No es necesaria la tradición de la cosa, sea mueble o inmueble, para adquirir la posesión, cuando la cosa es tenuta a nombre del propietario, y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro”. En cambio, el art. 2381 del Cód. Civil dice: “La posesión de las cosas muebles se toma únicamente por la tradición entre personas capaces, consintiendo el actual poseedor en la transmisión de la posesión”.

Los juristas civiles tratan de resolver la inconsistencia entre ambas normas interpretando que el adverbio *únicamente* se refiere al requisito de que los que adquieren u otorgan la posesión sean capaces, y no a la exigencia de tradición.

Las contradicciones normativas deben distinguirse de otras situaciones que podríamos denominar contradicciones *axiológicas* y que frecuentemente confunden los juristas con las primeras.

Hay una contradicción axiológica cuando la solución que el sistema jurídico atribuye a un caso indica, según ciertas pautas valorativas, que otro caso debería tener una solución diferente de la que el sistema prevé para él. Así ocurriría notoriamente si, por ejemplo, un derecho estableciera una pena de 20 años para quien matara a otro y de sólo 10 años para cuando la víctima fuera el cónyuge.

Veamos dos ejemplos de nuestro sistema positivo:

— El art. 209 del Cód. Penal reprime con pena de prisión de dos a seis años al que instigare públicamente a cometer un delito determinado, por la sola instigación. Esta figura requiere que la instigación se haga públicamente, pero no exige que el delito instigado se ejecute efectivamente.

A su vez el art. 45 del Cód. Penal establece que el instigador de un delito tendrá la misma pena que el autor del mismo. Esta instigación requiere que el delito instigado se cometa o se intente cometer.

Puede ocurrir perfectamente que la instigación de un delito que de hecho se comete (como en las injurias o el hurto), tenga pena menor que la establecida para la instigación de ese delito en el caso de que no se lo llegue a cometer.

Esto ha sido observado por los juristas como una contradicción —valorativa— del Código Penal.

— Otro caso en que, con mucha más claridad todavía, advierten los juristas una contradicción axiológica, lo constituye el juego de los arts. 138 y 139, inc. 2º, del Cód. Penal.

El primer artículo reprime con seis meses a dos años de prisión a quien alterare el estado civil de otro con el propósito de causar perjuicio.

La exigencia de perjuicio permite que no se castigue según esta norma los conocidos casos en que, con finalidad generosa, se recoge un niño huérfano y se lo hace aparecer como si fuera consanguíneo.

Sin embargo, el art. 139, inc. 2º, reprime con una pena mucho mayor —de uno a cuatro años— a quien por un acto cualquiera hiciere incierto, alterara o suprimiere el estado civil de un menor de 10 años. Esta norma no exige perjuicio.

De este modo, cuando se quiere beneficiar a un niño haciéndolo pasar por hijo, se tendría una pena mucho mayor que, por ejemplo, cuando se deseara heredar a alguien, con exclusión de los herederos legítimos, alterando el estado civil de aquél.

b) *La redundancia normativa*

Al igual que la inconsistencia, la redundancia se caracteriza por el hecho de que el sistema estipula un exceso de soluciones para los mismos casos, pero, a diferencia del anterior problema, aquí las soluciones no sólo son compatibles, sino que son reiterativas.

La redundancia requiere, por consiguiente, estas dos condiciones: primera, que ambas normas tengan el mismo campo de referencia, que se refieran a los mismos casos; segunda, que estipulen la misma solución para ellos.

Del mismo modo que en el caso de las normas contradictorias, la redundancia puede clasificarse en: *total-total*, *total-parcial* y *parcial-parcial*, según que los ámbitos de aplicación de las normas con soluciones equivalentes se superpongan totalmente, comprendan uno al otro y se refieran además a otros casos, o se superpongan parcialmente, manteniendo cada uno de ellos, además, referencias autónomas.

La redundancia normativa no tendría por qué crear problemas por sí sola para la aplicación del derecho, puesto que al seguirse una de las normas redundantes se satisfaría también lo prescripto por la otra. Sin embargo, la dificultad de la redundancia radica, como dice Ross, en que los juristas y los jueces se resisten a admitir que el legislador haya dictado normas superfluas y en consecuencia se esfuerzan por otorgar, a las normas con soluciones equivalentes, ámbitos autónomos. Así acaece sobre todo cuando las descripciones de dos normas con soluciones idénticas mantienen entre sí una relación lógica de equivalencia o implicación; en cambio, tal pretensión de reformular las normas no se presenta tan frecuentemente cuando la redundancia

aparece por la circunstancia contingente de que algunos casos encuadran en dos normas con descripciones lógicamente independientes y soluciones idénticas.

Vamos a poner otros ejemplos de redundancia en nuestro derecho, correspondientes a las especies que acabamos de mencionar:

—El art. 86, inc. 2º del Cód. Penal, antes de su reforma por la ley 21.388, eximía de pena por el delito de aborto cuando “el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

La expresión *atentado al pudor* admitía dos significados según se requiriera o no acceso sexual. El fundamento para no requerir acceso sexual era que una expresión análoga a aquélla —“*ultraje al pudor*”— es usada por el mismo Código Penal para hacer referencia a ataques sexuales que no implican coito. Sin embargo, resulta extraño que un embarazo provenga de un acto que no constituya acceso carnal.

Por lo tanto, la alternativa que restaba era entender que la expresión *atentado al pudor* supone coito. Pero resulta que el acceso sexual, con una mujer idiota o demente es, según el art. 119, inc. 2º, del Cód. Penal, una violación. Consecuentemente había en el art. 86, inc. 2º, una redundancia, puesto que la violación que produce un embarazo estaba ya prevista como causal de impunidad para el aborto. El afán de evitar esa redundancia llevó a muchos juristas a volver sobre la primera alternativa interpretativa, imaginando casos insólitos, y divertidos, de embarazos sin coito.

Un ejemplo de redundancia contingente se puede obtener de cualquiera de los casos en que la ley establece distintas alternativas no excluyentes que llevan a una misma solución. Por ejemplo, el art. 80 del Cód. Penal estipula una pena de prisión o reclusión perpetua, para quien, entre muchas otras hipótesis, matare a su padre o matare a alguien con alevosía. Si en un caso alguien mata a su padre y lo hace con alevosía, su conducta estará comprendida en dos normas que le imputan soluciones equivalentes, las cuales, naturalmente, no se acumulan.

—El art. 44 de la ley 18.880 de locaciones disponía:

“La presente ley deberá aplicarse de oficio en los juicios que no tuvieran sentencia firme a la fecha de entrar en vigencia. Los juicios fundados en causales que esta ley no prevé o cuando, habiéndolas previsto hubiese modificado los requisitos exigidos por su procedencia, podrán ser desistidos por los interesados sin perjuicio de su derecho a iniciarlos nuevamente si correspondiere. Las costas del juicio desistido se impondrán en el orden causado. La presente ley no se aplicará a las causas que a la fecha de su entrada en vigencia hubieren concluido con sentencia firme”.

Como se advierte fácilmente, las frases subrayadas son redundantes.

c) *Las lagunas del derecho*

Los dos defectos anteriores tienen en común que el orden jurídico presenta una superabundancia de soluciones, ya sean incompatibles o equivalentes, para un mismo caso. Hay, en cambio, una laguna del derecho cuando el sistema jurídico carece, respecto de cierto caso, de toda solución normativa.

Como lo han puesto de manifiesto Alchourrón y Bulgin en un trabajo difícilmente superable sobre los sistemas normativos, no tiene sentido hablar de lagunas del derecho si no se hace referencia a un cierto sistema jurídico y a un caso determinado. Un caso puede no estar solucionado por un sistema, pero sí por otro; a su vez, un sistema jurídico puede no estipular soluciones normativas para un determinado caso, pero, obviamente, contendrá soluciones para otros.

Los autores mencionados definen el concepto de laguna normativa como sigue (me permito obviar ciertos tecnicismos que exigirían larga explicación): *un cierto caso constituye una laguna de un determinado sistema normativo, cuando ese sistema no correlaciona el caso con alguna calificación normativa de determinada conducta (o sea con una solución).*

En esta definición se utiliza la palabra “caso” en un sentido genérico, que hace referencia a clases de acontecimientos (por ejemplo, cuando hablamos del caso de homicidio emocional), no a hechos individuales (como el homicidio cometido por Pedro). Los casos que se consideran para determinar la existencia de lagunas, son los pertenecientes a un *universo de casos* constituido a partir de que estén presentes o ausentes ciertas propiedades relevantes. Por ejemplo, si tomamos dos propiedades: 1) que haya error y 2) que haya violencia en la formación de un contrato; los casos serán cuatro, según haya violencia y error, error, pero no violencia, violencia y no error, o no haya ni violencia ni error. En cuanto a las soluciones posibles, hay que partir de la acción cuyo encuadramiento jurídico pretendemos determinar (por ejemplo, la de ejecutar judicialmente un contrato) y relacionarla con las distintas calificaciones normativas que ella y su omisión pueden recibir [puede estar permitida la acción de que se trata y también la omisión de ella —facultamiento (F)—, estar permitida la acción, pero no su omisión —obligatoriedad (O)—, o

no estar permitida la acción, pero sí su omisión —prohibición (Ph)].

Podemos ilustrar la definición explayando un ejemplo que ya hemos insinuado: si nuestro problema es determinar en qué casos corresponde la ejecución judicial de un contrato y las propiedades relevantes son que haya o no error o que haya o no violencia (E y V, respectivamente), se configurarían, como vimos, los casos siguientes (el signo “—” indica ausencia de la propiedad en cuestión):

$$\begin{array}{l} \text{— E y — V} \\ \text{E y — V} \\ \text{E y V} \\ \text{— E y V} \end{array}$$

Supongamos que un determinado sistema jurídico x faculta la ejecución en el primer caso, la prohíbe en el segundo y el tercero, y no dice nada respecto del cuarto; o sea:

$$\begin{array}{l} \text{— E y — V} \rightarrow (x) \text{ F ejecución} \\ \text{E y — V} \rightarrow (x) \text{ Ph ejecución} \\ \text{E y V} \rightarrow (x) \text{ Ph ejecución} \\ \text{— E y V} \rightarrow (x) \end{array}$$

Tendríamos entonces configurada una laguna normativa del sistema en cuestión (x), en relación a un determinado caso (—E.V) y respecto de una cierta conducta (la ejecución del contrato).

Una vez expuesto el concepto de laguna normativa o lógica, conviene hacer referencia a la negativa de muchos juristas y filósofos del derecho a admitir esa clase de lagunas en los sistemas jurídicos, o sea a su presuposición de que los órdenes son necesariamente completos.

Un paradigma de esa posición es la de Hans Kelsen. Este autor sostiene que el derecho no puede tener lagunas, puesto que para todo sistema jurídico es necesariamente verdadero el llamado principio de clausura, o sea un enunciado que estipula que *todo lo que no está prohibido está permitido*. Es decir que, cuando las normas del sistema no prohíben una cierta conducta, de cualquier modo tal conducta recibe una calificación normativa (su permisión) en virtud del principio de clausura que permite toda acción no prohibida.

Como ya lo adelantamos en el capítulo IV, Alchourrón y

Bulygin hacen una aguda crítica a este razonamiento. Omitiendo muchas distinciones técnicas que dificultan la comprensión de la crítica en este nivel expositivo, los lineamientos de las observaciones que los mencionados autores hacen a la opinión de Kelsen son los siguientes:

La expresión “permitido” que aparece en el principio “todo lo que no está prohibido está permitido”, puede tener dos significados diferentes. Uno es equivalente a “no prohibido”, o sea, implica que *no existe* en el sistema una norma que prohíba la conducta en cuestión. El otro hace referencia a una autorización positiva, o lo que es lo mismo, requiere la *existencia* de una norma que permite la acción de que se trata.

Si en el principio de clausura la palabra “permitido” se usa en el primer sentido, es decir como no prohibido, el principio debe leerse así: “todo lo que no está prohibido, no está prohibido”. Obviamente, este enunciado tautológico es necesariamente verdadero para cualquier sistema normativo, simplemente por aplicación del principio lógico de identidad. Pero también es obvio que, así interpretado, el llamado “principio de clausura” no sirve para completar un sistema, o sea para eliminar sus lagunas. Esto es así, ya que lo que el principio indica es la trivialidad de que si, en el sistema, no hay una norma que prohíba la conducta en cuestión, no existe una norma que prohíba tal conducta, de lo cual naturalmente no se infiere que exista otra norma que permita la acción. Es decir que con esta interpretación del principio de clausura, éste no impide que se dé un caso en que el sistema no contenga ni una norma que prohíba la acción de que se trata ni una norma que la permita, o sea que haya una laguna.

Con el segundo significado de “permitido” el principio de clausura rezaría así: “si en un sistema jurídico no hay una norma que prohíba cierta conducta, esa conducta está permitida por otra norma que forma parte del sistema”.

De acuerdo con esta segunda interpretación, el principio de clausura deja de ser una mera tautología trivial, para convertirse en un enunciado de contenido empírico. Sin embargo, su verdad es meramente contingente; no se la puede predicar *a priori* respecto de todo sistema jurídico, pues depende de que, efectivamente, en el sistema de que se trate exista una norma que autorice toda conducta no prohibida. Incluso se pueden dar ejemplos reales de muchos sistemas jurídicos respecto de los cuales ese principio no es verdadero (particularmente los de Estados autorita-

rios). Aun en los derechos correspondientes a regímenes democráticos, la autorización de toda conducta no prohibida tiene aplicación plena sólo en el ámbito penal, siendo muy relativa en los demás ámbitos jurídicos.

En síntesis, si el principio de la clausura es necesariamente verdadero, lo es sólo a costa de constituir una tautología que no elimina las lagunas. Si, en cambio, tiene un contenido empírico que describa la existencia de una norma permisiva de toda conducta no prohibida, se convierte en un enunciado contingente, que sólo será verdadero respecto de algunos sistemas jurídicos.

La única vía para eludir esta alternativa de hierro, es otorgar al principio de clausura el carácter de un enunciado sintético necesario.

Este camino es el que sigue Carlos Cossio. Sostiene este autor que la permisión de toda conducta no prohibida se da necesariamente en todo sistema jurídico, puesto que la conducta humana, que es el objeto del derecho, contiene siempre, como parte de su esencia, la libertad de realizarla. El derecho puede poner restricciones a esa libertad, prohibiendo ciertas acciones, pero cuando no lo hace, resurge la permisión de la conducta, que es un componente ontológico de ella.

Esta tesis sólo puede admitirse, como dicen Alchourrón y Bulygin, si se está dispuesto a aceptar verdades metafísicas, expresadas en enunciados sintéticos necesarios que describan supuestas estructuras ontológicas de la realidad. De cualquier modo, según aclaran los mismos autores, no es necesario encarar esa discusión filosófica, puesto que la posición de Cossio no supone que no haya lagunas *en el sistema jurídico*, sino que sostiene que las *acciones humanas* tienen una permisibilidad intrínseca que se pone de manifiesto cuando el derecho no califica normativamente una conducta.

Por último, Alchourrón y Bulygin descalifican también la posición sostenida, por ejemplo, por Del Vecchio y Recaséns Siches y según la cual el derecho no tiene lagunas porque ofrece medios para que los jueces puedan eliminarlas.

Según los mencionados autores, esto es tan irrazonable como decir que los pantalones no pueden tener agujeros, porque siempre hay sastres que los remiendan. Es decir que, del hecho de que haya remedios jurídicos para solucionar los casos de lagunas, no se puede inferir que éstas no existan.

Conviene decir algunas palabras sobre la situación de los jueces ante las lagunas del derecho.

El art. 15 del Cód. Civil argentino dispone: "*Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, obscuridad o insuficiencia de las leyes*".

La pregunta que sugiere la lectura de este artículo es cómo se las arreglan los jueces para dictar sentencia cuando el derecho no tiene una solución para un caso determinado.

Uno de los recursos más usuales que se utilizan en caso de lagunas, es la interpretación por analogía, que está indicada por el art. 16 del Cód. Civil.

La analogía consiste en asimilar el caso no calificado normativamente a otro que lo esté, sobre la base de tomar como relevante alguna propiedad que posean en común ambos casos. Claro que este procedimiento no se aplica mecánicamente y, cuando se lo aplica, deja al juez un amplio margen de arbitrio, ya que todo caso imaginable se parecerá a otro en algún aspecto y se diferenciará de él en otros muchos.

En el derecho penal moderno la analogía está vedada, no admitiéndose que los jueces extiendan las normas penales a comportamientos no previstos por ellas y que deben ser calificados como lícitos, en aplicación del principio "*nullum crimen, nulla poena, sine lege praevia*" (estipulado, en el sistema argentino, por el art. 18 de la Constitución Nacional).

Otros procedimientos a los cuales suelen recurrir los jueces para llenar las lagunas de los sistemas jurídicos, como la apelación a los llamados "principios generales del derecho", a la "naturaleza jurídica de una institución", etc., se estudiarán en el capítulo siguiente. (Ver también cap. VII, § 4 d.)

Veamos a continuación algunos ejemplos de lagunas normativas en nuestro derecho positivo:

— El art. 69 de la Constitución Nacional dispone que una vez aprobado un proyecto de ley por el Congreso, debe pasar al Poder Ejecutivo y, si lo aprueba, debe promulgarse como ley. Por otra parte, el art. 72 establece que el Poder Ejecutivo puede vetar total o *parcialmente* un proyecto, debiendo en tal caso remitírselo al Congreso para que lo discuta nuevamente.

Se plantea un problema en el caso de que el Poder Ejecutivo vete parcialmente un proyecto de ley. ¿Puede el Presidente promulgar como ley la parte del proyecto que no ha sido vetada, remitiendo al Congreso para su revisión sólo la parte impugnada? O, en cambio, ¿deberá remitir todo el proyecto al Parlamento para que lo revise en

su totalidad, absteniéndose de promulgar la parte no vetada? La Constitución guarda silencio a ese respecto.

La discusión se actualizó hace pocos años en ocasión de la ley 16.881, sancionada el 30 de marzo de 1966, que regulaba el régimen general de los contratos de trabajo. El Poder Ejecutivo la vetó parcialmente, promulgando cuatro artículos de la ley que se referían a la actualización de los montos indemnizatorios por despido. La jurisprudencia declaró inconstitucional la ley así promulgada por el Presidente, fundándose principalmente en 'que la promulgación de artículos aislados de una ley rompía la estructura del proyecto que el Parlamento quería sancionar.

Sin embargo, en otros casos, como en algunos en que se vetaron parcialmente ciertos artículos de leyes de presupuesto y se promulgó el resto, se admitió la constitucionalidad de aquel procedimiento.

— El art. 131 del Cód. Civil, según la reforma de la ley 17.711, estipula que los menores de 21 años, pero mayores de 18, podrán obtener la mayoría de edad (que ordinariamente se adquiere a los 21 años) si los habilitan expresamente sus padres o, en caso de no tenerlos, pero estar bajo tutela, el juez civil, a pedido del tutor o del menor. El Código no establece ninguna prescripción acerca de si corresponde o no la emancipación en el caso de un menor que no tenga ni padres ni tutor designado.

— El art. 3284 del Cód. Civil establece que son jueces competentes para entender en un juicio sucesorio los del último domicilio del causante (o sea, de la persona fallecida cuya sucesión se quiera tramitar). Constituye excepción a esta regla la circunstancia de que el causante haya tenido el último domicilio en el extranjero, pero tenga bienes inmuebles en el país, puesto que según el art. 10 del Cód. Civil, los bienes inmuebles situados en la República se rigen por nuestras leyes. Se plantea un problema cuando el causante haya tenido su último domicilio en el extranjero y posea inmuebles en distintas provincias del país.

¿Cómo se determina la jurisdicción provincial en la cual debe tramitarse el juicio sucesorio?

El Código no establece ninguna solución al respecto. La doctrina entiende que la sucesión puede tramitarse en cualquier provincia donde existan bienes.

— La legislación civil argentina no establecía ninguna solución normativa respecto del uso, por parte de la mujer casada, del apellido del marido. Algunos juristas, como Borda, Spota, Llambías, Lafaille, etc., entendían que constituía tanto un derecho, como un deber, cuyo incumplimiento podría constituir una de las causales de divorcio. Otros autores, como Cermesoni, Morello y Salas, sostenían que el uso del apellido marital era un derecho de la mujer, pero no una obligación. Un fallo plenario de la Cámara Civil de la Capital Federal del 23 de diciembre de 1966, había decidido, por nueve votos contra siete, que existe obligación de usar el apellido del marido derivada de las costumbres sociales. La ley 18.248 recogió esta solución.

— La ley de sociedades comerciales 19.550 no establece, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, ninguna prescripción directa en relación a la mayoría necesaria para disponer un aumento del capital de la sociedad.

Además del concepto de laguna *normativa* que acabamos de explicar y ejemplificar, tenemos que exponer la noción de laguna *axiológica*. (valorativa), que muchos juristas confunden con el primer concepto.

Alchourrón y Bulygin caracterizan las lagunas axiológicas de acuerdo con estos lineamientos:

Cuando el sistema normativo establece una solución para un caso constituido a partir de ciertas propiedades, son irrelevantes, en relación con la solución estipulada, las restantes propiedades que se puedan dar contingentemente junto con las que configuran el caso.

Por ejemplo, si el derecho estipula una solución para un caso constituido por las propiedades *E* y *V*, la solución no varía, a menos que haya otra norma que lo estipule, si se da un caso que tenga, además de *E* y *V*, la propiedad *R*.

Una propiedad es relevante para un sistema normativo si este sistema imputa a los casos configurados por esa propiedad una solución diferente de la que corresponda a los casos en que no se dé esa propiedad. A la inversa, una propiedad es irrelevante para un sistema normativo si éste soluciona de igual modo los casos en que tal propiedad aparece y los casos en que no aparezca.

Sin embargo, una propiedad irrelevante para el derecho puede ser relevante de acuerdo con ciertos criterios axiológicos. Si el derecho estipula, por ejemplo, la prohibición de la conducta *s* cuando se dan las propiedades *E* y *V* —siendo irrelevante para tal prohibición que además se dé la propiedad *R*—, se puede disentir de lo estipulado y pretender, de conformidad con ciertos criterios axiológicos, que se tome a *R* como relevante, de tal modo que, ante su presencia, deba prescribirse la permisión de *s*. En ese caso habría una laguna axiológica.

Una laguna axiológica se daría, pues, cuando un caso está correlacionado por un sistema normativo con una determinada solución y hay una propiedad que es irrelevante para ese caso de acuerdo con el sistema normativo, pero debería ser relevante en virtud de ciertas pautas axiológicas.

Las lagunas valorativas no se dan toda vez que el sistema jurídico estipula una solución injusta para un caso, sino cuando tal injusticia se funda en la consideración de que debería tomarse como relevante una propiedad que para el derecho no lo es.

Como hemos dicho, las lagunas axiológicas se confunden muchas veces con las lagunas normativas. Sin embargo, es obvio que en los casos de lagunas valorativas el derecho estipula una solución para ese caso. Lo que ocurre es que, como los juristas y jueces consideran que el legislador no hubiera establecido la solución que prescribió si hubiera reparado en la propiedad que no tomó en cuenta, concluyen que la solución estipulada, pero que les resulta irrazonable o injusta, no debe aplicarse al caso, constituyéndose una laguna.

Vamos a mencionar algunos pocos casos en los cuales se ha considerado que hay lagunas axiológicas en nuestro sistema jurídico:

— La ley 13.252, que regulaba el régimen de adopción hasta su sustitución por la ley 19.134, prohibía la adopción en el caso de que el adoptante tuviere ya hijos consanguíneos. Se entendió que el legislador no había previsto el caso de quien tuviera hijos consanguíneos mayores de edad y consintieren ellos en la adopción, situación en la cual se suponía completamente irrazonable aplicar la prohibición de la ley que es en beneficio de los hijos de sangre. Así lo decidió un fallo plenario de la Cámara Civil de la Capital Federal del 16 de diciembre de 1959. El nuevo régimen legal recogió este criterio.

— A pesar de que en el derecho penal moderno no hay lagunas en virtud del principio de reserva que convierte en lícitos los comportamientos no prohibidos, los penalistas suelen hablar muchas veces de “lagunas”, lo cual sólo puede tener un sentido axiológico.

Uno de los casos en que se solía advertir una laguna en nuestro Código Penal estaba dado por el juego de los arts. 164 (robo), antes de su reforma por la ley 21.338, y 168 (extorsión). El primero reprimía a quien con fuerza sobre las cosas o *violencia física* sobre las personas se *apoderara* de una cosa. El segundo castigaba a quien con *intimidación se hiciera entregar* una cosa. Muchos juristas habían anotado que estas dos normas dejaban una doble laguna: el que con intimidación (por ejemplo, amenazando con un revólver) se *apoderara* de una cosa ajena no cometería robo por no haber *violencia física*, ni extorsión, porque se habría *apoderado* de una cosa, no habría *obligado a entregarla*; el que con *violencia física se hiciera entregar* una cosa, tampoco cometería robo, por no haber *apoderamiento*, ni extorsión, por no haber *intimidación*.

No obstante la prohibición de aplicar la analogía en el derecho penal, en general la jurisprudencia había descartado la solución per-

misiva que surge del principio de reserva, comprendiendo en la expresión "violencia física" la intimidación.

— Un caso célebre de laguna axiológica en el derecho penal era la que presentaba el Código de Tejedor en relación al secuestro extorsivo de cadáveres. Estando vigente ese código, en el siglo pasado surgió una banda, denominada "Los caballeros de la noche", que se dedicaba a robar cadáveres pertenecientes a familias ricas, con el fin de exigir rescate. No se los pudo castigar, puesto que aquel código sólo reprimía la exhumación de cadáveres con el fin de mutilarlos o profanarlos.

A partir de 1887 se incluyó en los sucesivos códigos penales la especie del secuestro de cadáveres para obtener rescate.

— A propósito del caso anterior, nuestro Código Penal contiene, según el pensamiento de algunos autores, una laguna axiológica respecto de los cadáveres, puesto que no prevé, como relevante para la prohibición, el robo, lesiones o mutilaciones de ellos.

d) *La inoperancia de ciertas normas jurídicas*

Es obvio que muchas normas jurídicas son parcial o totalmente ineficaces. Se suele poner como ejemplo de esto en nuestro derecho los casos de la norma constitucional que prescribe el juicio por jurados y las normas del Código Penal que reprimen los duelos. Pero la ineficacia normativa no constituye un problema de aplicación de normas identificadas como pertenecientes al sistema, sino que incide en la pertenencia misma al sistema de las normas de que se trata (véase sobre esto el capítulo III).

En cambio, sí plantean problemas de interpretación los casos de normas que no *pueden* ser aplicadas por razones independientes de las de su aceptación o rechazo. En esos casos generalmente surge la preocupación por asignar a esas normas un significado distinto del original, proveniente de la preocupación, por parte de los jueces y juristas —que analizaremos en el próximo capítulo—, de que el legislador no pudo haber dictado normas imposibles de aplicar.

1) La imposibilidad de aplicar una norma puede deberse al hecho de que su condición de aplicación no puede darse, o a la circunstancia de que la conducta que la norma prescribe es de imposible cumplimiento.

a) Respecto de la *condición* de la norma, su imposibilidad puede ser lógica, empírica o normativa.

Es *lógicamente* imposible que se dé el antecedente de una norma si constituye una contradicción. Por ejemplo, una norma

no podría ser aplicada si estableciera algo tan disparatado como esto: "cuando una persona soltera cometiere bigamia, deberá ser reprimida con la mitad de la pena correspondiente al caso de que el autor fuere casado".

La imposibilidad *empírica* de que ocurra la condición de la norma se presentará cuando se trate de un hecho que esté en contra de las leyes naturales. Ejemplificaría este caso una norma que dijera: "cuando el aborto fuera cometido después del doceavo mes de embarazo, deberá ser castigado con 10 años de prisión". Esto es lo que Alf Ross llama una "falsa presuposición fáctica".

Por último, la condición de una norma es *normativamente* imposible que ocurra cuando está en pugna con lo dispuesto por otra norma. Esto ocurriría si una norma del derecho argentino dijera: "las personas menores de edad que hayan adoptado un hijo, deberán hacerlo conocer a su propio padre o tutor"; esta norma sería de imposible aplicación porque nuestra ley de adopción prohíbe que adopten los menores de 35 años. Este defecto es denominado por Ross "falsa presuposición normativa".

b) La *conducta* que la norma prescribe realizar, puede ser *lógicamente* imposible, haciendo inaplicable la norma, si está descrita en forma contradictoria. Por ejemplo, se daría este caso si una norma dijera: "por las rutas del país deberá tomarse la mano derecha, de modo que los vehículos que vienen en sentido contrario puedan pasar por la derecha del propio vehículo". Estos casos pueden analizarse fácilmente como constituidos por dos normas contradictorias, por lo cual el problema no es otro que la inconsistencia normativa de que ya hemos hablado y que constituye un caso límite de inaplicabilidad de normas.

La obligación puede referirse a una conducta que es *empírica* o técnicamente imposible de realizar. Esto se podría ejemplificar con una norma que dijera: "la demanda laboral siempre debe notificarse al demandado por telegrama colacionado", y se diera el caso de que no llegara el servicio telegráfico hasta el domicilio del demandado. Lo mismo ocurriría, obviamente, con las normas que prescriben penas de prisión si resultara que, en el lugar donde debería cumplírselas, no había prisiones, o no había plazas disponibles en ellas.

En fin, la imposibilidad *normativa* de ejecutar una acción ordenada se da cuando el cumplimiento de ella requiere alguna circunstancia que está prohibida por otra norma. Supongamos

que haya una norma que obligue en todo contrato de locación, cualquiera que sea su monto, a formalizar un seguro en la Caja Nacional de Ahorro, habiendo otra norma que prohíba a esa institución contratar seguros. No se trata propiamente de una inconsistencia normativa tal como la hemos definido, pues aquí la conducta que se manda y la que se prohíbe son diferentes, ya que corresponden a distintas personas, aunque la ejecución de la primera exija la cooperación de la última.

2) Hay casos en que una norma es inaplicable, no por la imposibilidad de ejecutar el comportamiento ordenado, sino, viceversa, porque tal conducta es *necesaria*. La norma es, entonces, superflua.

El paralelo con la imposibilidad no se extiende a la condición de aplicación de la norma cuyo antecedente es necesario (por ejemplo, “se perciban rentas o no, debe presentarse la declaración de réditos”), porque tal norma es equivalente a una norma categórica, perfectamente aplicable.

La necesidad de la conducta prescripta puede ser de carácter *lógico*. Se daría este caso si una norma dijera: “solamente deben ser castigadas por adulterio las personas casadas”.

También puede ocurrir que la acción ordenada sea *empíricamente* necesaria. Así acaecería si, por ejemplo, una norma dispusiera: “los médicos deberán abstenerse de resucitar a personas fallecidas”.

Por último, podría darse el caso de que la conducta que la norma obliga a realizar fuera necesaria por razones *normativas*. Esto se da, como caso límite, en la redundancia normativa, que ya hemos analizado, y también en otros casos que no satisfacen estrictamente la definición de “redundancia”, pues ambas normas no se refieren a la misma conducta. Por ejemplo, si hubiera una norma administrativa que prohibiera a los funcionarios recibir notas de particulares que no estuvieran redactadas en papel de oficio, sería superflua otra norma que dispusiera la obligación de los particulares de presentar en papel de oficio sus peticiones ante la administración pública.

Como se habrá advertido por la naturaleza de estos defectos, es muy difícil que en un derecho relativamente elaborado se presenten fallas de esta índole. Sin embargo, se pueden encontrar algunos ejemplos en nuestro derecho positivo:

— Al hablar de redundancia, hemos citado el caso del art. 86, inc. 2º, del Cód. Penal, en su redacción original, que declaraba impune el aborto cuando el embarazo hubiera provenido de una violación o atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. Dijimos que la expresión *atentado al pudor* se podía entender que implicaba acceso carnal —con lo cual resultaría redundante con *violación*—, o que excluía el coito. En este segundo caso la norma resultante era inaplicable ya que es empíricamente imposible el embarazo sin coito.

— El art. 2451 del Cód. Civil estipula: “*La posesión se pierde cuando el objeto que se posee deja de existir, sea por la muerte, si fuese cosa animada, sea por la destrucción total, si fuese de otra naturaleza o cuando haya transformación de una especie en otra*”. Respecto del párrafo subrayado, Julio Dassen comenta: “Con razón observa Legón que la disposición es inoperante: es claro que, si desaparece el objeto, no puede existir *relación posesoria* por simple imposibilidad lógica y jurídica”.

— El art. 4031 del Cód. Civil establece en su primer párrafo: “*Se prescribe también por dos años, la acción de nulidad de las obligaciones contraídas por mujeres casadas sin la autorización competente*”.

Este artículo tenía sentido en relación al art. 55 del Cód. Civil originario que convertía en incapaz relativa a la mujer casada, siendo nulas las obligaciones contraídas sin la intervención de su representante legal, que era el marido. Ya la ley 11.357 había restringido considerablemente los actos jurídicos que la mujer casada no podía ejercer por sí misma. Actualmente, la ley 17.711 reconoce la capacidad plena de la mujer casada, por lo cual el art. 4031, si bien no ha sido derogado, carece de aplicabilidad.

5. La interpretación del derecho jurisprudencial

Los presupuestos y problemas de interpretación que hemos examinado están en relación con las normas jurídicas sancionadas a través de oraciones lingüísticas por órganos legislativos. Como hemos dicho al comienzo de este capítulo, no todas las normas jurídicamente relevantes tienen aquel origen, sino que muchas se originan en costumbres sociales y en la actividad judicial. También respecto de estas normas se plantean graves problemas de interpretación.

Es conveniente decir algo a propósito de la interpretación del derecho jurisprudencial. Las normas de origen judicial, no sólo constituyen el núcleo más importante de algunos sistemas jurídicos —el llamado *common law* vigente sobre todo en Inglaterra y los Estados Unidos—, sino que, hasta en los sistemas de

tipo *continental europeo*, como el nuestro, tienen una vigencia no desdeñable para la solución de los casos. Podría decirse que la distinción entre los sistemas del *common law* y los de tipo continental se limita a una cuestión de grado respecto de la extensión de las áreas cubiertas por la legislación o por las normas jurisprudenciales y a la mayor o menor fuerza obligatoria que se asigne a cada una de esas especies de normas (fuerza obligatoria que en el caso de los precedentes se denomina *stare decisis*).

Incluso en las materias que en nuestro sistema están cubiertas por la legislación se va dando lugar a reglas jurisprudenciales que sirven para especificar una interpretación de los textos legales.

La determinación de las normas jurisprudenciales relevantes para solucionar un caso se hace mediante un complicado proceso que se funda en el llamado "razonamiento mediante ejemplos", o sea en la comparación entre casos, uno de los cuales ha sido clasificado ya bajo cierto concepto.

Edward Levy distingue tres fases en el razonamiento mediante ejemplos. La primera consiste en descubrir semejanzas entre el caso que se debe resolver y otros casos ya resueltos. En segundo lugar, se hace explícita la regla a que obedeció la solución de los casos anteriores. En la última fase se aplica aquella regla al caso planteado.

El primer tramo del razonamiento ofrece grandes dificultades. ¿Qué casos anteriores deben tomarse en cuenta para obtener una regla aplicable al que se debe resolver?

El principal criterio para la selección de precedentes es la *analogía* que deben guardar los casos fallados con el que se pretende solucionar. Pero no hay reglas para establecer qué semejanzas entre los casos son relevantes y qué diferencias son irrelevantes.

Una detallada descripción de los casos anteriores y del presente mostrará seguramente muchas diferencias. Sólo a medida que se avanza a un alto nivel de abstracción en la descripción de los casos, omitiendo muchas circunstancias, se pueden obtener descripciones equivalentes. No hay pautas para determinar hasta qué grado de generalidad está permitido llegar en la descripción de los casos con el fin de mostrar sus rasgos análogos.

También se toman en cuenta para la selección de los precedentes la jerarquía y antigüedad del tribunal del cual emanan.

Un tribunal se considera fuertemente obligado por sus propias decisiones anteriores y por las de los jueces superiores. Respecto de la antigüedad, a medida que los precedentes se alejan en el tiempo, van perdiendo fuerza vinculante, aunque no siempre lo reconocen así explícitamente los jueces del *common law*.

En cuanto al segundo paso del razonamiento mediante ejemplos —la obtención de la regla a que se ajustaron los precedentes—, también presenta dificultades.

En el *common law* se entiende que los jueces no están obligados por las afirmaciones explícitas hechas por los otros jueces (ni siquiera por las que ellos mismos pudieron haber hecho acerca de la regla aplicable para la solución del caso), que se consideran simples *obiter dicta*, es decir afirmaciones que no son necesarias para fundamentar el fallo. Lo que los obliga es la *ratio decidendi* de los fallos anteriores, es decir el principio general que explica las decisiones adoptadas. O sea que lo que los jueces, una vez que han seleccionado los precedentes, están obligados a realizar (a la luz de su propio punto de vista y no constreñidos a aceptar el de sus colegas que anteriormente hubieran fallado) es a formular una regla que sirva para explicar las decisiones que se hayan adoptado en los tales casos anteriores. Deben sentar un criterio razonable del cual se infieran las soluciones de los precedentes, aunque ese criterio no sea el mismo que enunciaron los jueces que dieron aquellas soluciones.

Es evidente que en este tramo del razonamiento también el juez goza de una considerable libertad. Las mismas decisiones pueden ser explicadas según reglas que pueden tener mayor o menor amplitud y diferentes excepciones y condiciones.

En el tercer tramo del razonamiento, la regla obtenida se aplica al caso que se debe juzgar. Tiene que decidirse si ese caso entra o no en el ámbito de aplicación de la regla, si constituye una de las excepciones que ella prevé, o si cae más bien dentro del marco de otra regla obtenida a través de una línea jurisprudencial distinta de la alegada. Es obvio que, en buena medida, la decisión estará determinada por la descripción que se haya dado del caso que se debe solucionar.

Una vez fallado el caso, los jueces, que tendrán que decidir en procesos futuros, contarán con un nuevo precedente que, determinada su analogía con el que tengan a examen, deberán incorporar al conjunto de decisiones que están obligados a explicar mediante alguna regla jurídica.

Se advierte, por lo tanto, que las normas jurisprudenciales tendrán que ir variando con los nuevos casos que deben ser resueltos. Cada nueva ocasión que se presenta para aplicar la regla da lugar a un enriquecimiento de ella mediante nuevas precisiones, condiciones y excepciones a fin de hacer compatible la norma con la solución que se adopte para el caso planteado.

En el sistema continental europeo el razonamiento respecto de los precedentes es menos cuidadoso y complejo, puesto que la regla *stare decisis* se aplica casi exclusivamente a lo resuelto por el mismo tribunal en otros casos o por tribunales superiores, y aun así mismo se procede con notorias franquicias. Los jueces no se sienten tan obligados a formular una regla que explique las decisiones de los otros jueces junto con la propia, si su decisión puede fundarse con una razonable interpretación de los textos legales.

6. La interpretación de las normas jurídicas y la administración de justicia

Lo que hemos visto en este capítulo se refiere a los problemas que se presentan cuando se pretende determinar qué normas jurídicas son relevantes para resolver un caso, ya se intente obtener esas normas de textos dotados de autoridad legal o de precedentes judiciales.

La mención de esos problemas basta para descalificar la concepción tradicional sobre la actividad judicial, originada en la escuela de la exégesis francesa y la jurisprudencia de conceptos alemana, que caracteriza la tarea de los jueces como consistente en la aplicación mecánica de ciertas reglas a determinados casos, sin que los jueces tengan la posibilidad —ni la función— de efectuar una reelaboración de tales reglas.

Se ha dicho muchas veces que tal concepción clásica considera el razonamiento judicial como un *silogismo*, cuya premisa mayor es la norma jurídica aplicable, la premisa menor vendría a ser la descripción del hecho que se juzga, y la conclusión, la solución del caso.

En verdad no hay nada de malo en considerar el razonamiento judicial como un silogismo. Lo incorrecto es pensar que las premisas del razonamiento judicial —las normas jurídicas relevantes y la descripción de los hechos decisivos—, se obtengan

por procedimientos mecánicos. Como lo han señalado Alchourrón y Bulygin, no es que los jueces no realicen un razonamiento deductivo al fundamentar una decisión, sino que la elección de las premisas y las reglas de inferencia de su razonamiento exigen una verdadera labor creativa.

Este punto ha sido ya mostrado a lo largo de las páginas anteriores en relación con las premisas normativas del razonamiento judicial, cuyo alcance debe ser, en buena parte de los casos, reformulado por los jueces para salvar las imperfecciones de los textos legales o de los precedentes judiciales. Como hemos visto, la tarea de precisar los textos vagos o ambiguos, eliminar las lagunas y las contradicciones, determinar los precedentes relevantes, etc., por lo común no está guiada por reglas precisas de segundo nivel y, cuando lo está, o sea cuando son aplicables principios tales como el de *lex superior* o el que indica que se apele a las soluciones de casos análogos, no es infrecuente que se tropiece con reglas competitivas que aportan soluciones divergentes.

En cuanto a la determinación de las premisas fácticas del razonamiento de los jueces, es obvio que también ella presenta agudas dificultades. El conocimiento de los hechos relevantes debe obtenerse a través de complicados sistemas de pruebas y presunciones que las más de las veces dejan a los jueces un amplio margen de apreciación personal, dando lugar en muchos casos a descripciones discordantes respecto de las conclusiones que se pretenden inferir de los mismos datos empíricos.

Alf Ross presenta un esquema interesante para entender la supersimplificación que hace la concepción tradicional respecto de la actividad judicial. Parte de la tesis de Stevenson de que toda acción es la resultante de ciertas creencias y de determinadas actitudes (o motivos, o propósitos). La variación de uno de esos factores, manteniéndose los demás, provoca una acción diferente. Por ejemplo, dos legisladores pueden sustentar la misma creencia de que la pena de muerte provoca una disminución de la delincuencia, pero mientras uno de ellos adopta una actitud favorable a obtener ese resultado a cualquier costo, el otro no está dispuesto a admitir que se disponga de la vida como medio para conseguir aquel objetivo; en consecuencia, el primero propugnará la pena de muerte en tanto que el otro se abstendrá de imponerla. Lo mismo sucedería si, viceversa, ambos legisladores estuvieran dispuestos a luchar contra el crimen por cualquier medio, pero uno

de ellos no creyera que la pena de muerte fuera un medio eficaz, mientras que el otro estuviera convencido de ello.

Con este esquema, sostiene Ross que la teoría clásica respecto de la administración de justicia, consideraba las decisiones judiciales como resultantes, exclusivamente, de estos factores: *a)* en cuanto a las creencias, un conocimiento pleno de las leyes aplicables y de los hechos relevantes que se deben juzgar; *b)* en lo que atañe a la actitud, una pulcra conciencia jurídica formal, es decir el deseo de aplicar estrictamente las leyes sin ninguna otra consideración.

Ross sostiene que este planeamiento constituye una burda caricatura de lo que ocurre en la realidad, en la cual las decisiones de los jueces son el producto, por lo menos, de estos elementos: *a)* en relación a las creencias, no sólo el conocimiento, que generalmente es imperfecto, por lo que ya dijimos, de las normas jurídicas vigentes y de los hechos planteados, sino también de toda una serie de circunstancias de orden político, social, económico, que rodearon tanto a la sanción de las normas jurídicas como a la producción del hecho propuesto al examen del juez; *b)* y en cuanto a las actitudes, la conciencia jurídica formal de los jueces compite casi siempre con su conciencia jurídica material, o sea con el deseo de llegar a una solución valorativamente aceptable, de modo que no es infrecuente que los jueces tengan que plantearse el dilema de aplicar estrictamente la ley, dando lugar a una solución injusta, o apartarse de ella, para decidir satisfactoriamente el caso planteado. (Como hemos visto en el primer capítulo, los jueces son tan moralmente responsables como todos nosotros, y el mero hecho de fundar sus decisiones en normas jurídicas positivas no los exime de su responsabilidad moral por tales decisiones.)

Este cuadro no lo presenta Ross como algo deseable, sino como correspondiente a lo que de hecho ocurre, aun en las épocas y en los ámbitos en que la concepción tradicional tenía mayores adherentes. La verdad es que en diferentes tiempos y ámbitos puede variar el peso relativo de las distintas creencias y actitudes, por ejemplo haciendo los jueces mayor abstracción de las circunstancias que rodearon a la sanción de la ley y a la producción del hecho y dando mayor predominio a la conciencia jurídica formal sobre la material; pero esas oscilaciones nunca llegan al extremo de satisfacer el esquema de la teoría tradicional.

En cambio, lo que sí registra profundas diferencias es la

medida en que los jueces *reconocen* que deben reelaborar las normas jurídicas dadas, que no son inmunes a la percepción del marco social que envuelve a la sanción de tales normas y al caso planteado y que están provistos, no sólo del deseo de someterse a las leyes, sino también del de obtener soluciones axiológicamente satisfactorias. Y es ahí, en cuanto al reconocimiento de esos factores, donde pueden advertirse enormes variaciones; desde una negativa absoluta hasta una admisión sin ambages.

En nuestro ámbito, los jueces son, en general, marcadamente renuentes a admitir explícitamente que, en muchas ocasiones, deciden bajo la influencia de consideraciones de índole pragmática acerca de las consecuencias sociales de cada una de las soluciones posibles. Cuando ocurre lo contrario, resulta llamativa la actitud del juez.

Se puede ver esto con claridad a través de un ejemplo (que fue comentado por Jorge A. Bacqué y este autor en un artículo): El Código Penal argentino agrava los delitos de robo y daño cuando se los comete en *banda*. La palabra "banda" aparece también en la descripción del delito de asociación ilícita, que se reprime en forma separada de los delitos que los miembros de la asociación puedan cometer. Se discutió si, para que haya banda en la comisión de un robo o daño, deben darse los requisitos de la asociación ilícita (en especial, que concurren tres o más personas). En el caso de respuesta afirmativa, no podría castigarse acumulativamente a un individuo por haber cometido un robo en banda y por formar parte de una asociación ilícita, puesto que se lo penaría dos veces por el mismo hecho. En cambio, si "banda" y "asociación ilícita" se interpretan como expresiones con significado diferente, podrán sumarse las penas del robo o el daño en banda y las de la asociación ilícita.

La tesis primera fue recogida por un plenario de la Cámara Criminal de la Capital, habiendo tenido particular relevancia en la decisión final la opinión del vocal doctor Ernesto J. Ure.

No obstante, en 1963 el mismo tribunal modificó el criterio, adoptando la tesis de la acumulación de penas. Es obvio que tuvo que haber influido decididamente en el cambio de enfoque de la Cámara el notable aumento de la delincuencia organizada que se produjo entre ambos plenarios y la creencia de que un aumento de penalidad podría ser un recurso apropiado para combatirla.

Pero, a pesar de aquella evidencia, la consideración de las consecuencias sociales de las soluciones posibles no se pone de manifiesto más que en la argumentación del doctor Ure, quien expresamente alude a "la realidad social circundante" y a la necesidad de defender a la sociedad contra los delitos llevados a cabo por varios individuos. Los demás jueces, incluso uno de ellos que también cambió su opinión expresada en el fallo de 1944, fundamentaron el nuevo criterio en

argumentos de carácter técnico y en la supuesta interpretación objetiva de la ley.

El hecho de que se mantenga en un plano no reconocido la actividad de los jueces de reelaborar las normas jurídicas generales hace difícil el control público de sus decisiones y de los criterios axiológicos en que las fundamentan. Esto puede constituir a veces un grave obstáculo para los cambios sociales cuando la ideología del cuerpo judicial no coincida con los propósitos de los legisladores y de la opinión pública que pretenden tales cambios. Conviene precisar algo más esta cuestión.

7. Derecho, administración de justicia y cambios sociales

W. Friedmann señala que hay dos opiniones contradictorias respecto de la habilidad del derecho para servir como instrumento de cambios sociales, que pueden ilustrarse con las posturas de dos grandes juristas: Savigny y Bentham.

Savigny, como lo hemos expuesto en el primer capítulo, expresaba la concepción historicista respecto del derecho. Según él, el derecho se encuentra, no se hace. El derecho está en el espíritu del pueblo, en las costumbres sociales. La legislación sólo debe actuar una vez que los juristas han aceptado y articulado las pautas vigentes en la sociedad. Propugnaba, por lo tanto, una actitud pasiva del derecho ante las circunstancias sociales, lo cual lo inducía a ser denodado enemigo de la codificación, que en su época se expandía por Europa. Su punto de vista influyó resueltamente en otros juristas, como Ehrlich, para quien había que dar preferencia al "derecho vivo del pueblo" sobre las normas coactivas del Estado. Estas últimas debían limitarse a regular cuestiones relacionadas con la organización militar, policial y tributaria.

Bentham, en cambio, creyó fervientemente en la capacidad del derecho como instrumento de reforma social y se dedicó a lo largo de su vida a redactar códigos para distintos países (desde Rusia hasta algunas naciones latinoamericanas). A su prédica se debe, en buena parte, la concepción moderna del parlamento como un cuerpo activo que, por medio de la legislación, puede efectuar cambios sociales, ya respondiendo a necesidades de la sociedad, ya estimulando nuevas expectativas.

Aunque la concepción de Savigny tuvo una marcada influen-

cia entre los juristas y filósofos del derecho, promoviendo la idea —que tiene sus raíces en el pensamiento de filósofos griegos y juristas romanos—, de que el derecho está más allá de toda manipulación racional dirigida hacia objetivos sociales, el punto de vista de Bentham terminó por imponerse. Ello no se debió tanto a una conversión de los juristas, sino a que las intensas transformaciones sociales, por ejemplo las originadas en la revolución industrial, la organización sindical de los trabajadores y el proceso de urbanización, que obligaron a adoptar medidas legislativas más o menos rápidas, pusieron en evidencia la función instrumental del derecho respecto de la obtención de objetivos sociales.

Hoy en día resulta muy difícil negar la influencia recíproca entre el derecho y las circunstancias sociales y económicas.

Los cambios producidos en la sociedad se reflejan, más tarde o más temprano, sobre el ordenamiento jurídico y éste, a su vez, suele servir de promotor de nuevas pautas sociales (lo que no se concilia fácilmente con la idea marxista de que el derecho es parte de la “superestructura” de una sociedad y como tal, se limita a reflejar y proteger el sistema de producción existente y los intereses de la clase dominante).

No quiere esto decir que haya siempre una coordinación plástica entre las circunstancias sociales y las normas jurídicas vigentes.

Son frecuentes los casos en que se produce un retraso de la legislación respecto de las demandas de la opinión pública, ya por impermeabilidad de los legisladores, ya por la existencia de poderosos grupos de presión en sentido contrario, ya en fin porque el procedimiento de reforma legislativa en ocasiones es lento y complicado.

Esto se puede ilustrar en nuestro país con la falta de respuesta legislativa para los innumerables casos de familias irregulares a causa de la inflexibilidad de la legislación matrimonial.

También son comunes las situaciones inversas, en que la población se resiste a aceptar reformas promovidas por la legislación.

Algunos filósofos jurídicos, como Hart y Lon Fuller, han señalado ciertos recaudos mínimos, formales y materiales, que el derecho debe satisfacer para tener alguna probabilidad de ser eficaz, como proveer a que los súbditos tengan posibilidad de

conocer las normas jurídicas o disponer algunas limitaciones para los ataques contra la vida humana.

Sin llegar a esos extremos, la legislación suele a veces resultar ineficaz ante los hábitos profundamente arraigados en la población.

Por ejemplo, se han realizado investigaciones sociológicas sobre el influjo de la implantación de la legislación occidental en Turquía, demostrándose que, mientras las normas que se referían a aspectos instrumentales, como las actividades comerciales, consiguieron una aplicación efectiva, las relacionadas con cuestiones afectivas o creencias primarias, como la vida familiar y el matrimonio, sólo escasamente lograron alterar las pautas sociales aceptadas.

En nuestro medio esto ocurrió con evidencia, por ejemplo, con las normas referentes al duelo, practicado en el pasado despreocupadamente por ciertos grupos sociales no obstante las severas sanciones del Código Penal, y con las normas relativas al aborto, que no pueden contener la extensión de esa práctica en la sociedad, generándose un grave problema moral.

Los sociólogos jurídicos suelen formular algunas condiciones necesarias para que una norma jurídica pueda tener éxito en su empeño por alterar los hábitos arraigados en una sociedad. Por ejemplo W. M. Evan señala las siguientes condiciones: *a*) que la norma jurídica en cuestión emane de una autoridad prestigiosa (indica el autor que en los Estados Unidos se advierte menor resistencia potencial a las nuevas normas legislativas que a las jurisprudenciales); *b*) que la nueva norma pueda fundamentarse como compatible con ideas jurídicas, culturales, etc., ya aceptadas; *c*) que se permita a la gente visualizar modelos prácticos de cumplimiento de la norma; *d*) que se haga uso consciente del factor temporal para permitir que vaya cediendo paulatinamente la resistencia a la norma; *e*) que los agentes encargados de aplicar la norma se comprometan, por lo menos externamente, a su cumplimiento, sin dar muestras de hipocresía, corrupción o privilegio; *f*) que se empleen premios y castigos adecuados para motivar el cumplimiento de la norma, y *g*) que se provea protección efectiva a aquellos que se vieran afectados por el incumplimiento de la norma.

Los cambios que el derecho introduce en la sociedad pueden clasificarse, como lo sugiere Y. Dror, en directos e indirectos. El derecho produce cambios sociales directamente cuando las

conductas que regula significan, por sí mismas, alguna alteración de las condiciones sociales preexistentes (por ejemplo, si se prohíbe la poligamia en un país donde antes regía); por el contrario, los cambios son producidos indirectamente por el derecho cuando éste crea algún modo de protección, institución, autoridad administrativa, etc., que con el tiempo pueden ir dando lugar a conductas innovadoras (por ejemplo, si se crea una ley de protección a las patentes de invención y ella promueve una intensa renovación tecnológica).

El estudio de la posibilidad de promover cambios sociales a través del derecho se ha concentrado generalmente en la creación de normas jurídicas por los órganos legislativos. Sin embargo, la aplicación que los jueces hacen de las normas jurídicas a casos concretos no tiene menos relevancia en cuanto a las posibles consecuencias sociales.

Los problemas de interpretación que se han venido analizando a lo largo de este capítulo, son demostrativos de que los legisladores tienen limitaciones para prever todos los casos posibles y asignarles solución.

De hecho, parte del poder legislativo está transferido implícitamente al cuerpo judicial, quien, como vimos, muy a menudo tiene que reelaborar las normas que le ofrece el legislador antes de aplicarlas a los casos concretos.

Esa tarea de reformulación de las normas generales normalmente tiene ante sí, como también dijimos, diferentes alternativas. En muchos casos la elección de una u otra interpretación por parte de los jueces tiene consecuencias sociales relevantes.

La necesidad de resolver casos particulares hace que la magistratura advierta, en muchos casos con más facilidad que los legisladores, efectos sociales inconvenientes de una disposición legal, razón por la cual procede a realizar una interpretación correctiva de aquélla para impedir tales consecuencias.

Pero también se suele dar el caso de un cuerpo judicial de tendencia conservadora, que frustre, con interpretaciones limitativas, los propósitos de cambio social del legislador. Fue famosa, en este sentido, la actitud de la Corte Suprema norteamericana ante las disposiciones, que importaban una marcada transformación social y económica, inspiradas por el presidente F. D. Roosevelt.

En esos casos los jueces se refugian en el argumento de que sus soluciones se apoyan en la "verdadera" y "única" interpreta-

ción de la Constitución o de la ley, ignorando las restantes alternativas interpretativas que los textos legales pueden ofrecerles.

Un remedio adecuado para reducir la frustración de los propósitos legislativos a través de la interpretación judicial, puede ser un mayor realismo de los legisladores en el reconocimiento de las imperfecciones de las leyes que sancionan para resolver unívocamente todos los casos futuros; después de lo cual no deberían limitarse a prescribir a los jueces el empleo de meras técnicas formales de interpretación, que, como en el caso de la analogía, por lo común pueden servir para justificar soluciones dispares. En cambio, tal vez los legisladores podrían tener mayor eficacia en la concreción de sus propósitos, si formularan reglas materiales de interpretación que indicaran la preferibilidad de las soluciones que tuvieran determinadas consecuencias sociales o que promovieran ciertos objetivos o valores.

Los jueces tienen influencia sobre los cambios sociales, conteniéndolos o estimulándolos, no sólo a través de la reformulación de las normas jurídicas generales, sino también mediante el control de los procedimientos judiciales.

Una decisión que podría tener efectos sociales inadmisibles a juicio del juez, puede a veces evitarse sacando provecho de irregularidades procesales cometidas por la parte que la reclama.

En los países latinos, y sobre todo en los de origen hispano, el procedimiento judicial suele ser engorroso, lleno de formalidades solemnes y en general elusivo al control por parte de la opinión pública.

Todavía se advierten, en esos ámbitos, resabios de una actitud mágica ante el procedimiento judicial, según la cual, pronunciar ciertas palabras o cumplir ciertas fórmulas es condición necesaria y suficiente para obtener determinados efectos jurídicos.

Estos obstáculos en el procedimiento judicial son, obviamente, regresivos respecto de la capacidad del derecho de influir en la realidad social. Crean una actitud ritualista y medrosa en los abogados y en la gente en general, quienes terminan por ver el proceso judicial como un juego del que saldrá triunfador quien supere todos los obstáculos y haga caer a la otra parte en el mayor número posible de trampas, en vez de enfatizar la discusión sobre los intereses que constituyen el telón de fondo del pleito y sobre su compatibilidad con principios de moralidad social.

Por último, un procedimiento judicial exageradamente formalista, principalmente cuando exige, como en nuestro país, la escritura, impide el adecuado control por parte de la opinión pública de los procesos y las decisiones judiciales. No sólo a causa del ámbito reservado en que se desarrollan los juicios, sino principalmente porque se ocultan los intereses en juego y el significado social de la decisión

adoptada tras de discusiones acerca de la satisfacción de las formas procesales.

Todos estos factores inciden evidentemente en que, en muchas ocasiones, los cambios sociales propugnados por los órganos legislativos no puedan concretarse a través del aparato judicial.

Estas observaciones no deben dar la impresión de que la magistratura desaliente siempre deliberadamente las reformas sociales y vaya a la zaga de los legisladores en sus propósitos reformistas. La cuestión, sin duda, es contingente según la composición de los cuerpos legislativo y judicial en distintas épocas y ámbitos y la materia de que se trate (y la valoración de la actitud de los diferentes órganos frente a los cambios sociales dependerá, obviamente, de la valoración de tales cambios sociales). No es excepcional que los jueces propendan a reajustar las normas generales a las circunstancias sociales anticipándose a los legisladores y eludiendo con más facilidad las presiones que se ejercerían contra una reforma legislativa. Por ejemplo, nuestros jueces advirtieron que las normas que reprimen el aborto se aplicaban casi exclusivamente a las mujeres pobres que, habiendo sufrido lesiones a raíz de las maniobras abortivas, debían internarse en un hospital público, cuyos médicos se consideraban obligados, como funcionarios estatales, a denunciar el delito. La Cámara Criminal de la Capital, en un plenario de 1966, decidió que los procesos penales así iniciados son nulos, porque la mujer procesada —no los cómplices— está en una condición análoga a quien se obliga a declarar contra sí mismo. De este modo y sin perjuicio de mantener la valoración negativa de este tipo de conductas, se condicionó radicalmente la punición del aborto, antes de que ningún legislador se hubiera manifestado sensible ante las circunstancias sociales que obligaban a las mujeres sin recursos, primero a decidirse a abortar, después a hacerlo en condiciones peligrosas y, por último, a recurrir a un hospital público, donde iban a ser probablemente denunciadas.

Lo que sí indica el desarrollo anterior es que hay ciertos obstáculos objetivos para que el cuerpo judicial, independientemente de las propensiones de sus integrantes, sea adecuadamente permeable a las transformaciones sociales propugnadas por los órganos políticos.

De las distintas dificultades que hemos señalado, la más interesante es la que se refiere a la elección de una alternativa interpretativa de las normas legisladas, justificándola en razones distintas de las consideraciones valorativas en favor y en contra de las diferentes opciones y encubriendo el hecho de que tales opciones se presenten.

A esta altura es conveniente preguntarse a qué clase de justificaciones recurren los jueces para fundar sus decisiones, si es que no se apoyan predominantemente en la justificación moral de cada una de las soluciones posibles, y cómo hacen para mantener en segundo plano la circunstancia de que, en muchas oca-

siones, tienen ante sí diversas alternativas de interpretación de las normas legales.

La respuesta es que el cuerpo judicial tiene a su alcance un admirable complejo de presupuestos y técnicas de argumentación suministrados por la "ciencia jurídica", que le permite cumplir la función de reelaborar las normas generales y, al mismo tiempo, hacerlo en forma no manifiesta.

El próximo capítulo estará dedicado, precisamente, a examinar tales presupuestos y técnicas de argumentación que la ciencia del derecho desarrolla y presta a los jueces.